

법철학에서 관습이 왜 중요한가?*

—관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해—

이현경**

〈국문초록〉

소위 ‘탈관습적 시대’로 불리는 오늘날 법이론과 법실무에서 관습(법)은 흔히 무관심과 냉대의 대상이 되어왔다. 국가법체계 안에서 관습법은 개념적 잉여가 아니냐는 회의론과 함께 관습의 역할은 종종 ‘법이론의 퍼즐’로도 논해진다. 한편, 법철학의 관점에서 보면, 관습법의 문제는 여러 차원에서 매우 중요하다. 특히 법실증주의자들에게 있어 관습법의 법적 지위 문제는 그들의 법개념관 안에서 반드시 풀어야 할 난제이자 이론의 성패를 좌우할 만한 도전적 과제였다. 반면 풀러 식의 비실증주의 진영에서 보면, 법의 상호작용성과 개방성을 강조하기에 가장 좋은 창구가 관습법일 수 있다. 이렇듯 관습의 문제에 어떻게 대처하는

DOI: 10.22286/kjlp.2021.24.2.010

* 이 논문은 서울대학교 법학전문대학원 학문후속세대양성센터의 연구지원을 받아 작성한 것이다. 물심양면으로 베풀어주신 지원과 격려에 지면을 빌어 깊이 감사드립니다.

** 서울대학교 법학연구소 책임연구원, 서울대학교 법학전문대학원 강사, 충북대학교 법학전문대학원 강사.

*** 투고일자 2021년 7월 31일, 심사일자 2021년 8월 19일, 게재확정일자 2021년 8월 21일.

지에 따라 각각의 법철학 이론의 완결성과 가치가 평가된다. 이 글에서 필자는 우선 관습의 본질과 법적 위상을 둘러싼 법철학 논쟁사를 비판적으로 검토하고, (II) 특히 명령주의적 실증주의나 회의론적 전통에서 문제시해온 ‘관습 없는 관습법’과 ‘관습법의 역설’ 현상을 중심으로 무엇이 관습을 ‘문제적’으로 만드는지를 논한다. (III) 그리고 관습(법)의 본질에 대한 새로운 이해를 위한 기초적인 분석틀로 ① “관습=관행*습관(화)”라는 정식을 제안하면서, ② 규범적 실천 설명법을 검토한다. (IV) 이렇게 규명된 관습의 특유성에 기초하여 관습의 권위와 법규정의 근거를 논한다. (V) 마지막으로, 적절히 재구성된 법적 관습 이론은 법철학의 난제가 아니라 국제관습법까지 포괄한 포용적인 법개념관의 토대가 되며, 관습법이 시대착오적인 법원이 아닌 미래사회를 위한 연성법규범의 다른 이름이 될 수 있음을 전망하면서 글을 맺는다. (VI)

I. 법철학의 천덕꾸러기 난제, 그 이름 ‘관습’

소위 ‘탈관습적 시대’¹⁾로 불리며 ‘입법 만능주의’를 특징으로 하는 오늘날 법이론과 법실무에서 관습(법)은 흔히 무관심과 냉대의 대상이 되어왔다.²⁾ 국가법체계 안에서 관습법은 개념적 잉여가 아니냐는 회의론이 끊임없이 제기되는데, 반면에 국제법영역에서 국제관습법은 제1의 법원(法源)의 위상을 가지면서 일종의 ‘모순적 공존’ 현상도 발견된다. 그 결과 법에서 관습의 역할은 ‘법이론의 퍼즐(puzzle)’³⁾로도 일컬어지곤 한다. 한편, 법철학의 관점에서 보면,

1) ‘탈관습적 시대’라는 표현은, 임미원, “탈관습적 시대의 규범적 논거들의 계보”, 『한양법학』, 2013.

2) Gerald J. Postema, “Conventions at the Foundations of Law”, in *The New Pargrave Dictionary of Economics and The Law*, Edited by Amanda Perreau-Saussine and James Bernard Murphy, Macmillan Reference Limited, 1998, p. 53.

3) 이와 유사하게 샤이너(Roger A. Shiner)는 ‘법리학적 퍼즐(jurisprudential puzzle)’이라고 명명한다. Roger A. Shiner, “Custom”, in *Legal Institution and the Sources of Law*, Springer, 2005, p. 63.

관습법의 문제는 여러 차원에서 매우 중요하다. 특히 법실증주의자들에게 있어 관습법의 법적 지위와 효력 문제는 그들의 법개념관 안에서 반드시 풀어야 할 난제이자 이론의 성패를 좌우할 만한 도전적 과제였다.⁴⁾ 반면 풀러(Lon L. Fuller)⁵⁾식의 비실증주의 진영에서 보면, 법의 상호작용성과 개방성을 강조하기에 가장 좋은 창구가 관습법일 수 있다. 이러한 문제의식 하에, 이 글에서 필자는 법이론과 법실무⁶⁾ 두 영역에서 소위 난제로 일컬을 수 있는 문제들을 공히 관통하는 주제로서 ‘관습(custom)’을 본격적인 법철학적 탐구의 대상으로 한다. 즉 법의 다양한 영역에서의 이론적·실천적 문제를 소통하고 난제를 해결하는 ‘열쇠 개념(key concept)’으로서 관습에 대한 철학적 분석과 대안을 모색한다. 특히 관습의 본질과 법규성에 대한 해명은 궁극적으로 법의 본성에 대한 우리의 이해를 풍부하게 하고 깊은 통찰을 제공할 것이다. 이 글에서 제안되는 관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해방식은 다양한 차원에서 존재해온 기존의 전형적인 이분법적 구도를 벗어나 법적 추론의 맥락에서 관습의 역할이나 기능을 중심으로 한 분석들을 전제로 한다. 논문의 구성은 다음과 같

4) 법개념론을 4개 입장-강한 자연법론, 약한 자연법론, 포용적 법실증주의, 배제적 법실증주의-으로 구분하고, 효력론을 ‘가치론적 효력론’, ‘체계론적 효력론’으로 나누어 각각의 법개념론과 법효력론을 연결 지어 논하고 있는 중요한 국내 연구로는, 최봉철, “법의 효력: 요건과 효과를 중심으로”, 『법철학연구』, 2014를 참고할 것.

5) 풀러의 저술 중 국내에 번역된 것은, Lon. L. Fuller (송성국, 김혁기 옮김), “실증주의 그리고 법에 대한 충실성-하트 교수에 대한 답변”, 『공익과 인권』, 2007; Lon. L. Fuller (박은정 옮김), 『법의 도덕성』, 서울대학교출판문화원, 2015; 풀러에 대한 국내 연구로, 최봉철, “풀러의 합법성론”, 『법철학연구』, 2004; 장영민, “하트-풀러 논쟁 50년 회고”, 『법학논집』, 2007; 강태경, “론 L. 풀러의 유노믹스”, 『법철학연구』, 2017 등 참고.

6) 법실무는 입법 실무와 사법 실무로 나눌 수 있다. 특히 사법 실무(judicial practice)와 관련해서, 최근 분묘기지권과 관련한 우리 최고법원들의 판례는 관습법과 관련하여 새로운 전환점을 제공한다고 볼 수도 있다. 그런데 필자의 분석에 따르면, 대법원 전원합의체 판결과 현재결정문 곳곳에서 확인되는 일부 법관들의 제정법중심주의적 사고와 논증은 한편으로 고전적 법실증주의자들의 환원주의적 분석과 매우 닮아있다. 이는 다른 한편으로 관습(법) 그 자체의 본질에 대한 심도 깊은 토대 연구가 부족함을 방증하기도 한다. 이를 통해, 가장 현장성이 강한 재판실무와 가장 근본적인 법철학 영역에서의 논의가 ‘지금 여기’, 현재적 관점에서 맞닿아 있음을 확인할 수 있다. 이 주제와 관련해서는 별도의 법철학적 판례 평석을 준비 중이다.

다. 우선, 관습의 본질과 법적 위상을 둘러싼 법철학 논쟁사를 비판적으로 검토하고, (II) 특히 명령주의적 실증주의나 회의론적 전통에서 문제시해 온 ‘관습 없는 관습법’과 ‘관습법의 역설’ 현상을 살펴본다. (III) 그리고 관습(법)의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해를 얻기 위한 대안을 모색한다. 이를 위한 출발점이자 기초적인 분석틀로 “관습=관행*습관(화)”라는 정식을 제안한다. 그리고 관습의 권위를 논한 후, ‘메타-관습’을 통한 관습법의 정당화를 살펴본다. (IV) 마지막으로, 적절히 재구성된 법적 관습 이론은 법철학의 서자가 아니라 국제관습법까지 포괄한 포용적인 법개념관의 토대가 되며, 관습법이 시대착오적 규범이 아닌 미래지향적 법원(法源)이자 다원주의 사회를 위한 연성법 규범의 다른 이름이 될 수 있음을 전망하면서 글을 맺는다. (V)

II. 관습의 법적 위상을 둘러싼 법철학 논쟁과 변천

이 장에서는 “법철학에서 관습이 왜 중요한가?”⁷⁾라는 물음에 대해 가장 직접적인 경로로 답을 구하기 위하여 법철학이론사 안에서 관습의 법적 위상을 둘러싼 논쟁의 흐름과 양상을 검토한다. 그리고 각 시기별 특징적인 논의 틀 안에서 핵심 쟁점에 대한 나름의 수정주의적 대안을 모색해본다. 다만, ‘논쟁

7) 참고로 ‘신행정수도의 건설을 위한 특별조치법 위헌결정’을 소재로 하여 ‘존재와 당위의 관계’, ‘관습(헌)법에서 관행과 승인’이라는 중요한 법철학적 문제를 다루고 있는 대표적인 연구로는, 고봉진, “관습헌법의 존재와 효력 — 신행정수도의 건설을 위한 특별조치법 위헌결정’을 중심으로”, 『법과 정책』, 2015; 양선숙, “수도-서울 명제의 ‘관습헌법’성립에 대한 비판적 검토”, 『법철학연구』, 2006 등 참고. 본고에서 직접적인 논점으로 다루고 있지는 않지만 ‘존재와 당위의 관계’는 법철학에서 매우 중요한 주제일 뿐만 아니라, 이는 ‘사실적인 것의 규범력’을 주장한 엘리네크의 헌법 이론과도 깊은 관련이 있다. 엘리네크는 ‘관습법’의 경우 존재와 당위의 일치를 확인할 수 있다고 주장한다. “사실적인 것의 규범적인 것에 대한 관계가 가장 날카롭게 나타나는 것은 법의 발생의 경우이다. 어떤 민족의 모든 법은 본래적으로는 사실적 관행 이외의 아무것도 아니다. 지속된 관행은 이러한 관행의 규범적합성의 관념을 창출하며, 또한 그것에 의해서 규범 그 자체가 공동체의 권위적 명령으로서, 즉 법규범으로서 보여지게 된다. 이로써 관습법의 문제 역시 그 해결을 보게 된다.” Georg Jellink(김효전 옮김), 『일반 국가학』, 법문사, 2005, 278면.

사'라는 특성에 비춰볼 때, 논의의 실익 상 관습의 법규성을 적극 옹호해 온 진영보다는 회의적 관점에서 나름의 극복을 시도하고자 했던 법실증주의 흐름을 중심으로 검토하고자 한다. [그런 차원에서 사비니(Friedrich Carl von Savigny)나 19세기 역사학파의 이론은 본 장에서는 필요한 한에서 제한적으로만 다룰 것이다.]

1. 고전적 법실증주의와 관습: 벤담, 오스틴과 회의주의적 전통

(1) “관습법”은 개념모순이고 잉여적인가?

흔히 ‘법명령설’(command theory of law)로 특징화되는 고전적 법실증주의자들에게 있어 관습은 그들의 법개념론 안에서 이론적으로 반드시 해명해야 할 일종의 장애물이자 도전적 과제였다고 볼 수 있다. 벤담(Jeremy Bentham)⁸⁾과 오스틴(John Austin)⁹⁾은 관습법이라는 발상 자체가 용어상 본질적 모순을 내포하고 있으며 “관습법”이란 것은 개념적 중복이나 잉여라는 비판론을 제시했다. 법의 본질을 주권자의 명령으로 이해하는 고전적 법실증주의자들은 법이란 입법부나 공식적인 정부 권위체에 의해 창조된다고 보았기에,¹⁰⁾ 법이 어떻게 보통 사람들의 실천으로부터 생겨날 수 있는지, 그리고 그 방식은 어떠한지에 관한 물음이 그들에게는 풀어야 할 숙제였던 셈이다. 가령, 관습의 법규성

8) 국내 법철학계에서 벤담에 대한 선도적 연구로는 이상영 교수의 연구를 들 수 있다. 이상영, “공리주의자의 헌법전 연구 — J. Bentham의 ‘헌법전’의 구성과 특징”, 『법학연구』, 2016; 이상영, “법실증주의의 선구자 J. Bentham은 이상주의자인가 혹은 현실주의자인가?”, 『법사학연구』, 2018; 이상영, “J. Bentham의 세계헌법 구상에 대한 소고 — 세계 공동 헌법?”, 『아주법학』, 2014; 이상영, “공리주의 대 자연권 — 프랑스 혁명과 자연권에 대한 벤담의 평가”, 『세계헌법연구』, 2010; 이상영, “벤담의 Common Law 체계에 대한 비판과 입법론 구상에 대한 연구”, 『서울대학교 법학』, 2008; 이상영, “벤담의 법개념과 입법론에 대한 소고”, 『세계헌법연구』, 2007 등 참고.

9) 국내 법철학계에 오스틴의 생애와 법사상에 대해 잘 정리하여 소개하고 있는 글로는, 권경휘, 김정오, “존 오스틴의 생애와 법사상”, 『법철학연구』, 2018; 김형석, “실증주의와 공리주의의 연결고리 — 존 오스틴의 명령으로서의 법 개념”, 『법학논총』, 2019 등 참고.

10) Frederick Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, *Texas International Law Journal*, Vol. 48, 2013, p. 523.

(legality)¹¹⁾도 주권자의 명령의 발행(issuance of orders by the sovereign)의 면에서 설명될 수 있는지, 만약 그러하다면 관습법이 제정법과는 어떻게 다른지 등에 관한 추가적인 물음이 제기될 수 있다. 법의 본성에 관한 고전적 법실증주의의 견해는 우리에게 주로 오스틴을 통해 전해졌기에, 관습법이 고전적 법실증주의자들의 관점 안에서 어떤 위상을 갖는지를 파악하기 위해서는 오스틴에 대한 탐구를 출발점으로 삼는 것이 유익하겠다.¹²⁾

(2) 주권자의 명령, 제재의 위협, 그리고 상향식 관습의 불안한 법적 지위

주지하듯이, 오스틴은 제재에 근거한 법모델을 주장했다. 법의 본성에 관한 오스틴의 기본적인 생각은 법은 제재의 위협을 배경으로 한 주권자의 일반적인 강제적 명령이며, 이는 법과 법적 의무나 책무의 본질적 부분을 이룬다.¹³⁾ 제재의 위협이 없이는 법은 공식적인 요청(official request)이나 제안과 별반 다르지 않으며, 따라서 오스틴에게 있어 ‘제재의 위협’은 요청과 제안을 법으로 바꾸는 일종의 ‘전환 기제’의 역할을 한다고 볼 수 있다. 물론 위협의 원천은 다

11) 법철학에서 ‘legality’는 ‘합법성’으로 번역되는 것이 일반적이다. 그런데 본고에서는 특별히 ‘법규성’으로 옮긴다. 그 이유는 ① 강학상 주로 실효성이나 정당성과 구별되는 의미에서의 합법성과는 의미 차이가 있고, ② ‘합법성’이란 용어는 한국어 표현의 어감상 제정법의 효력을 논하는 맥락에서 주로 사용되는 언어관용을 고려하며, ③ 관습법과 관련된 최근 대법원 판결문에서도 ‘관습법의 법적 규범성’ 혹은 “법적 규범으로서의 효력”이라는 표현을 사용하기에, 본고에서는 이를 축약하여 ‘법규성’으로 옮긴다. 가장 최근의 대표적인 판례로는 대법원 2021.4.29. 선고 2017다228007 참고.

12) 실제로 벤담은 현재 우리가 관습법이라고 이해하는 것 —정부의, 입법의 혹은 사법 판결로부터 유래된 것이 아니라, 공동체 규범으로부터 유래된 공동체의 규범적 실천—을 “전통법”라고 이름 붙였다. Jeremy Bentham, *Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence*, p. 161. (Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 525. 각주 15에서 재인용)

13) John Austin, *Lectures on Jurisprudence of the Philosophy of Positive Law*, Robert Cambell ed., London, John Murray, 5th ed., 1895; 주권자의 명령으로서 법의 원천에 대한 설명은, John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University Press, 5th, ed. 1995, p. 13, pp. 18-25. 샤우어는 오스틴의 이런 작업에 대해 “터무니없게 과도한 단순화(egregious oversimplification)”라고 비난조의 평가를 한 바 있다. Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 526.

양할 수 있지만, 오스틴에게는 최고 권력으로부터 나오고 제재에 의해 뒷받침되는 명령만이 ‘법’이라고 적절히 불린다.

관습의 법적 지위에 관한 만족스러운 설명이 왜 벤담과 오스틴의 관점에서 그토록 중요한 것일까? 그 이유는 관습이라는 기본 발상이나 개념정의에서의 핵심은 그것이 최고 권력자인 주권자(the sovereign)¹⁴⁾로부터 하명되는 것이 아니라 민중(the population)의 규범적 실천으로부터 상향식(bottom-up)으로 발생한다는 점에 있기 때문이다. 고전적 법실증주의자들의 관점에서 보면, 관습의 이러한 상향식 특성이 법으로서의 지위를 위태롭게 하는 한 원인이 되며, 그로 인해 관습의 법적 지위에 대한 설명은 불완전하게 남게 된다. 결국 법을 제재에 의해 뒷받침되는 주권자의 명시적 명령으로 이해하면서도 법체계 안에서 관습이 어떻게 법이 될 수 있는지를 설명하는 것이 오스틴에게는 중요한 과제였다. 이 문제에 대한 오스틴의 해결책은, 관습은 그 자체로는 법이 아니지만 주권자로부터 수권을 받은 판사에 의해 적절한 절차에 따라 채택되면 그때 비로소 법이 된다는 것이다. 판사는 주권자에 의해 (암묵적으로) 권위를 부여받은 자로서, 불준수의 경우에 위협을 가하거나 제재를 부과할 권위 역시 암묵적으로 수권 받았기 때문이다.¹⁵⁾ 결과적으로 오스틴에게 있어 관습과 법 사이의 연결고리는 파생적이고 간접적이다. 여러 단계를 거치기는 하지만, 주권자의 묵시적 명령 덕분에 관습은 법이 된다고 설명함으로써 범명령설의 정합성을 확보한 셈이다. 요컨대, 오스틴의 설명 안에서 ‘법으로서 관습’의 지위는 ‘관습과 주권(sovcreignty)’¹⁶⁾ 사이의 관련성, 주권자의 묵시적인 권한부여에 의

14) 오스틴의 법개념에 있어 주권자는 최고의 정치적 통수권자를 의미한다. 오스틴의 ‘주권자’ 개념의 문제점과 오류에 대한 하트의 비판은, H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3d ed. Penelope A. Bulloch & Joseph Raz & Leslie Green, Oxford University Press, 2012, Chap.2. 참고. [국내 번역서는, H.L.A. Hart (오병선 옮김), 『법의 개념』, 아카넷, 2001, 제2장]

15) Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, pp. 34-36, 141-142.

16) 고전적 법실증주의자들에게 있어 ‘주권’은 이론의 중심축을 이루는 핵심개념 중 하나다. 만약 범명령설의 기본 틀을 유지하면서도 적절한 수정을 통한 결함 극복을 시도한다면, 최우선적으로 가능한 것이 ‘주권 개념의 민주화’일 것이다. 말하자면 전통적인 주권개념에서 지배-복종의 논리를 전제로 한 최고성, 절대성 등의 요소를 제거하고 대신 ‘민주적 주권’ 관념을 구체화하는 방식으로 새로운 개념화 작업이 요청된다.

해 제공되는 ‘제재와 관습’ 사이의 관계에 기인한다.¹⁷⁾ 이런 환원주의적 설명에 대해서는 많은 비판이 제기되었고, 무엇보다 법의 본성에 있어 제재가 필수조건인지에 대한 근본적인 반성이 있다.

2. 현대 법실증주의(modern positivism)와 관습: 하트와 승인을

(1) 하트의 반-오스틴적(Anti-Austinian) 설명

법의 본성에 대한 오스틴의 기본적 설명은 19세기 중반부터 20세기 중반까지 백년 이상을 지배했다. 물론 수많은 비판과 교정이 있었지만, 기본적인 오스틴식 착상(the basic Austinian picture)은 법리학적 사유에 있어 하나의 패러다임을 제공했다. 하지만 1961년 하트(H.L.A. Hart)의 *The Concept of Law*¹⁸⁾가 출간되면서 오스틴식 착상은 권세를 상실했다.¹⁹⁾ 하트는 오스틴의 제재에 기반한 법 모델은 여러 점에서 결함이 있음을 지적하면서²⁰⁾ 그것을 대체할 대안적 설명을 제시한다. 하트의 반-오스틴적 입론의 핵심은, 법의 본성과 합법성의 필수조건으로 제재 요소를 제거하고 대신에 ① ‘1차 규칙과 2차 규칙들의 체계’로서 법을 정의 내리고, ② ‘궁극적 승인율’ 개념을 고안하고, ③ 규칙의 ‘수용’과 ‘내적 관점(internal point of view)’이라는 발상을 도입하여, 법의 내면화(internalization)를 설명의 중심에 놓는다.²¹⁾ 물론 하트도 제재 요소가 근대법체계에 만연해 있다는 점, 그리고 법준수의 보장이나 효율성 확보의 면에서 제재가 수행하는 개연적 유용성은 인정했다. 하지만 하트는 무엇이 법인지, 법 자

17) Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 526.

18) H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3d ed. Penelope A. Bulloch & Joseph Raz & Leslie Green, Oxford University Press, 2012.

19) Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 527.

20) 오스틴식 착상과 그의 법개념론이 갖는 여러 결함에 대한 하트의 비판은, Hart, *The Concept of Law*, Chap. 2.

21) 하트의 승인율과 내적 관점에 관한 국내 연구로는, 안준홍, “승인규칙의 규범성에 대한 일 고찰”, 『법철학연구』, 2013; 김건우, “하트의 내적 관점이란 무엇인가?”, 『법철학연구』, 2013; 권경휘, “현대법실증주의와 규범성의 문제: 하트의 ‘내적 관점’을 중심으로”, 『법철학연구』, 2015; 권경휘, “승인의 규칙에 관한 하트의 이론”, 『강원법학』, 2015; 강태경, “내적 관점의 중층 구조”, 『법철학연구』, 2018 등을 참고할 것.

격성을 인정하는 데에 있어서는 제재의 개념적 역할은 불필요하며, 이론상 전체 법체계는 제재 없이도 존재할 수 있다고 주장한다.²²⁾ 요컨대, 법에 대한 하트의 반(反)-오스틴적 설명은 ① 합법성의 존재에 있어 제재의 불필요성과 ② 오스틴식의 강력한 하향식 법 모델에 대한 거부를 나타낸다. 하트는 법의 본성에서 제재와 주권적 선포(sov​er​eign promulga​tion) 양자를 폐기함으로써 관습의 역할이나 법적 위상에 대한 반-오스틴적 설명을 제공할 수 있게 된다.²³⁾

(2) 궁극적 승인율의 내면화를 통한 법구성

하트에게 있어 법의 결정요인(determinant)은 궁극적 승인율이며, 그것의 지위는 ‘내면화의 함수(a function of internalization)’²⁴⁾다. 샤우어의 분석에 따르면, 만약 궁극적 승인율과 법의 토대에 있어 승인율의 내면화에 대한 하트의 설

22) 하트와는 다른 방식으로, 법의 본성에 대한 제재-독립적인 이해(a sanction-independent understanding of the nature of law)에 대한 불만과 논쟁을 다룬 글로는, Frederick Schauer, “On the Nature of the Nature of Law”, 98 *Archivfur Rechts-und Sozialphilosophie* 457, 2012; Frederick Schauer, “Positivism Before Hart”, 24 *CAN.J.L. & JURISP.* 455, 458, 2011; Danny Priel, “Sanction and Obligation in Hart’s Theory of Law”, 21 *Ratio Juris* 404, 2008 등을 참고할 것.

23) Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 528. 그런데 샤우어가 지적하듯이, 하트에게 있어 승인율은 관습을 법으로 인식할 수는 있지만 꼭 그럴 필요는 없었다. 더 정확히 말하자면, 사법적용 이전에 존재하는 법으로 관습을 승인할 필요는 없는 것이다. 또한 하트는 *The Concept of Law* 초반에 반-오스틴적 설명을 제시하면서 관습 문제를 언급하지만, 정작 그의 이론의 핵심을 이루는 여러 내용들(가령, 1차 규칙과 2차 규칙 사이의 구별, 2차 규칙의 다양성, 내적관점이라는 발상 등)을 제시한 이후에는 관습에 대한 문제로 다시 돌아가지 않았다. 물론, *The Concept of Law*에서 2차 규칙이 도입된 성숙한 법체계가 형성되기 이전의 전근대사회에서는 관습이 사회의 주된 규범이라고 설명한다. 하지만 이 부분을 과잉해석해서 관습은 전근대사회의 전속규범이라고 단정 짓는다면 심각한 잘못이다. 이와 관련하여 Shiner도 다음과 같이 지적한다. “우리는 하트를 그러한 과정을 원시적 법으로부터 발전된 법으로의 이행으로 특징화할 필요는 없으며, 논쟁적이긴 하지만 그래도 안된다.” Shiner, *Legal Institution and the Sources of Law*, Springer, 2005, p. 64. 따라서 우리는 관습의 법적 지위에 대한 하트 이론의 명시적이고 충분한 논증을 텍스트로부터 찾아내기보다는, 하트적 관점에 대한 이해와 적용, 그리고 그의 설명에 대한 정합적인 해석을 통해 하트의 대답을 이해할 수 있겠다.

24) 승인율이 ‘내면화의 함수’라는 표현은, Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 529.

명이 대체로 정확하다면 이는 관습의 법적 지위에 관해서도 상당한 시사점을 제공한다. 첫째, 만약 법 자체에 있어 ‘주권자의 명령’이 아닌 ‘규범의 내면화’가 핵심이라면, 관습은 더 이상 별개의 독특한 법리학적 공간(jurisprudential space)을 요하지 않는다.²⁵⁾ 말하자면, 성문법규나 (코먼로체계라면) 법으로서 사법 판결, 혹은 법으로서 헌법 조항에 그러하듯 관습에 대한 법이나 승인을 역시 같은 논리가 적용되는 것이다. 물론 하트의 텍스트 자체에서는 관습법의 법적 지위에 대한 명확하고 체계적인 설명은 확인하기 어렵다. 하지만 하트의 서술 전반에 대한 정합적인 독해를 해본다면, 그의 이론과 발상 안에서 그 어떤 요소도 관습의 법적 지위를 부인하거나 강요하지 않는다.²⁶⁾ 중요한 것은 해당 법체계에서 승인의 실천(practice of recognition)이 실현되고 구체화 되는 방식에 달려있다고 볼 수 있다.²⁷⁾ 생각건대, 하트에 대한 이러한 유연한 해석은 결국 궁극적인 승인의 실천을 포함한 규범적 실천의 중요성에 대한 인식과 함께, 그러한 실천을 통한 관습의 법적 지위 부여 가능성과 그것을 근거짓는 이론적 대안 모색으로 나아갈 수 있는 길을 열어 준다.²⁸⁾ 이는 필자가 방법론상 강조

25) “이러한 주장들이 참인 한, 관습의 법규성은 하트를 포함한 실증주의 전통에 있는 법이론가들이 해결하고자 했던 퍼즐이 아니게 된다. 대신에, 승인율의 내면화(internalization)는 관습을 그저 곤혹스러운 것으로 다루거나 더 넓은 실증주의적 그림 안에서의 일종의 부속물로 만드는 것이 아니라, 모든 법의 토대에 있어 중요한 구성요소이게 하는 식으로 가장 잘 설명된다.” Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 524.

26) 싸우어는 이론적으로는 다음의 세 가능성이 존재한다고 말한다. (i) 오직 일부 관습이나 일부 규범적 관습을 법으로 승인할 가능성, (ii) 모든 관습 혹은 모든 규범적 관습을 법으로 승인할 가능성, (iii) 그 어떤 관습도 법으로 승인하지 않을 가능성, 이런 가능성들이 특정 법체계의 존재와 일관성을 유지할 수 있다. Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, pp. 530-531.

27) 이 점은 다음의 문구와도 연결될 수 있겠다. “차이는 디테일에 있지, 그 기본적인 구상에 있지 않다.(The difference is in the details, but not in the basic picture.)” Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 531.

28) 필자의 이런 서술이 갖는 함의를 두 가지 점에서 언급하고자 한다. 첫째는, 관습의 본질과 법규성을 ‘규범적 실천’을 중심으로 이해할 필요가 있다는 본고 제4장 논의에 대한 일종의 예비적 탐구로도 볼 수 있다. 둘째는, 최근에 법실증주의의 세부 유형에 대한 새로운 분류들이 시도되고 있는데, 그중 ‘Social-Practice Legal Positivism’이라는 유형과도 친연성이 있다고 볼 수 있다. 이와 관련해서는, Stefano Bertea, “Social-Practice Legal Positivism and the Normativity Thesis”, in *The Cambridge*

하는 관행주의적 분석이나 실천-중심적 접근(practice-centered approach)과도 연결된다.

(3) 관습의 특유성을 몰각한 또 다른 환원주의

전항에서 소개한 하트의 반(反)-오스틴적 설명은 ‘궁극적 승인율의 내면화’를 법규성을 규정하는 본질적 요소로 삼는다. 그 결과 관습은 제정법이나 사법 판결과 같은 여타 법들과는 별개의 독특한 법리학적 공간을 요하지 않고 동일하게 취급된다는 샤우어의 주장은 과연 타당한가? 이에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다. 왜냐하면 이러한 분석에 따르면, 결국 관습의 특유성은 몰각되고 제1의 법원인 성문법규와 동일한 논리가 적용되게 된다. 무엇이 법인지를 승인하고 법규성의 근거를 제공하는 궁극적 승인율 역시 모든 종류의 법규범 혹은 법원(法源)을 아우르는 단일한 것으로 이해되어,²⁹⁾ 오스틴과는 또 다른 방식의 일원론적 환원주의³⁰⁾라는 비판을 받을 수 있다. 이러한 귀결은 이론의 검약성의 면에서는 큰 장점이 있지만 다른 한편으로는 관습이 본질적으로 갖는 고유성과 특수성을 무시한 과도한 단순화의 위험을 내포한다. 또한, 실제로 하트의 텍스트 자체가 정말 그러한 점을 의도하고 있는지, 그것이 하트에 대한 정확하고 올바른 독해인지에도 다소 의문이 든다. 예컨대 최소한 승인율을 구성하고 있는 세부 기준들(criteria)³¹⁾의 수준에서라도 ‘관습에 대한 승인율(the rule of recognition of custom)’³²⁾을 특화할 만한 이론적 자원을 충분히 발견할

Companion to Legal Positivism, Edited by Torben Spaak and Patricia Mindus, Cambridge University Press 참고.

29) 예컨대, 하트의 텍스트 안에서 “the sole criterion of identifying the law”라는 표현에 주목해 보자. Hart, *The Concept of Law*, p. 101.

30) 다만 혼동하면 안 되는 것은, 필자가 여기서 관습에 대한 궁극적 승인이라는 문제와 관련하여 하트의 승인율 이론에 내재하는 ‘일원론적 환원주의’의 가능성을 지적한 것이, 하트 이론 전반에 대한 ‘환원주의’를 말하는 것은 아니다. 오히려 하트의 법이론은 두 오스틴-John Austin과 J.L. Austin-과의 이론적 영향 속에서 ‘반환원주의’로 특징화될 수 있다. 철학적 관점에서 하트 법이론의 의의와 반환원주의를 지적한 연구로, 김현철, “하트 법이론의 철학적 의의에 대한 비판적 고찰”, 『법학논집』, 2007, 36-38면 참고.

31) Hart, *The Concept of Law*, pp. 100-109.

32) 하트가 제기한 승인율 개념은 영국을 배경으로 법실증주의 관점에서 고안된 것이

수 있다. 일종의 수정주의적 시도로서 더욱 정교하게 세분해 본다면, ‘관습에 법적 지위를 부여하는 승인율’이라는 발상에도 두 가지 가능성이 있을 수 있다. ① 성문법규와는 다른 유형의 별도의 독자적인 승인율이 존재할 가능성 혹은 ② 해당 법체계에서 궁극적 승인율의 종류는 하나인데, 다만 그것을 구체화하는 내부기준의 차원에서 규범 유형-제정법과 관습법-에 따른 내용 차이가 존재할 가능성이다. 이론의 실천력 면에서 보더라도, 그와 같은 획일주의적 취급은 미래지향적 관점에서 활용 가능한 관습 규범의 잠재성을 사전에 차단할 우려가 있다. 그런 점에서 보면, 관습의 특수성을 (의도적으로건 아니건) 간과한 체 제정법 중심주의를 전제로 한 환원주의적 접근으로 나아가는 정직된 실증주의 모델과 해석론은 부적절한 면이 있어 보인다. 이 점은 하트 이후 법실증주의 내부에서 ‘포함주의적 · 포용주의적³³⁾ 승인율’의 가능성을 둘러싼 실증주의 분파 논쟁과도 연결된다.

(4) “관습으로서 법(law as custom)”?

앞에 지적했듯이, 궁극적 승인율을 ‘규칙 그 자체’의 지위에 초점을 맞춰서, 말하자면 존재론 편향적으로 이해하지 않고 그것이 현실화되는 ‘궁극적인 승인적 실천’ 또는 그 역동적 과정에 더욱 주목해 본다면 관습의 법적 지위를 함의하는 “법으로서 관습(custom as law)” 혹은 “법원으로서 관습(custom as a source of law)”이라는 명제를 넘어 법의 본질을 관습의 면에서 이해해 볼 수도

다. 하지만 하트는 모든 법체계에는 반드시 하나 이상의 승인율이 존재하며, 이는 일반법철학에 해당한다고 하였다. 그렇게 본다면, 하트의 실증주의적 승인율 개념을 비실증주의, 혹은 관습법 등에 대한 응용모델도 충분히 생각해볼 수 있겠다. 이러한 문제의식을 발전시켜 ‘자연법론적 승인율’ 모델을 제시한 중요한 연구로는, 김도균, “자연법론적 승인율 모델의 가능성”, 『법철학연구』, 2000; 김도균, “자연법론적 승인율의 필연성에 대하여”, 『법철학연구』, 2001 참고.

- 33) 흔히 라즈적 배제적 법실증주의와 대립되는 연성 법실증주의 모델로 분류되는 것으로 ‘포용적 법실증주의(inclusive positivism)’와 ‘포함적 법실증주의(incorporate positivism)’가 있다. 전자를 주도하는 대표학자로는, 콜먼(Jules L. Coleman)을 들 수 있고, 후자의 대표로는 크레머(Matthew H. Kramer)를 들 수 있다. 양자는 세부 내용에서 차이가 있는데, 이는 본 고의 주제범위를 벗어나기에 여기서 상론하지는 않는다. Jules L. Coleman, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, 2000; Matthew H. Kramer, *Where Law and Morality Meet*, 2004 등 참고.

있다.

적어도 하트적 설명에서 보면, 법은 원칙적으로 ① (궁극적인 승인적) 실천의 내면화, 그리고 ② 그것을 규범적인 것으로 다루는 것이다.³⁴⁾ 가령, 만약 권위를 가진 누군가가 어떤 규범을 창안하고선 나름의 방식으로 유효하게(valid) 할 수 있다라도, 그것이 내부적으로 얼마큼 유효하든지 간에 국민과 법공직자들에 의해 수용되고 내면화되지 않는다면 여전히 한국의 법은 아닌 것이다. 다시 말해, 법적 지위를 수립하는 것은 ‘규범체계의 내면화’ 혹은 체계적인 승인율(a systemic rule of recognition)에 의한 ‘개별법의 내면화’이다.³⁵⁾ 하트에 따르면, ① 1차 규칙과 2차 규칙들의 결합이 존재할 때, 그리고 ② 궁극적 승인율이 특정한 종류의 공직자들에 의해 내면화될 때 법체계는 존재한다. 그런데 만약 하트의 텍스트를 약간만 왜곡시켜본다면, 규범을 법으로 바꾸는 것은 결국 실제적인 인간 실천(actual human practice)이고 그런 의미에서 ‘법은 그저 관습’³⁶⁾이라는 명제가 도출될 수 있다.³⁷⁾ 생각건대, “관습으로서의 법”이라는 테제는 한편으로는 사비니나 19세기 역사학과를 상기시키며, 다른 한편으로는 가장 최근에 법철학을 포함한 규범 철학 전반에서 부상하고 있는 실천 중심적 접근³⁸⁾과도 상통한다고 볼 수 있다. 하지만 하나의 테제로서 “관습으로서의 법”을 주장하기에는, 다른 규범적 질서들과는 달리 국가법체계가 갖고 있는 독특한 특성들 예컨대 ‘체계성(systemicity)’³⁹⁾과 같은 점들이 오히려 간과될 수 있다는 역

34) Hart, *The Concept of Law*, pp. 99-100.

35) Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, pp. 531-532.

36) Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 532.

37) 조금 다른 견해로, Shiner는 설령 대부분의 근대 법체계에서 관습법이 단지 “양적으로는 사소한 부분”에 머문다고 할지라도, 관습이 법을 존재하게 할 수 있다 (custom can bring into existence)라고 주장한다. Roger A. Shiner, “Law and Morality”, in *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, edited by Dannis Patterson, 1996. (Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 532에서 재인용)

38) 대표적으로 필자는 투오멜라의 연구에 주목한다. Ramio Tuomela, *The Philosophy of Social Practices: A Collective Acceptance View*, Cambridge University Press, 2002; Ramio Tuomela, *The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View*, Oxford University Press, 2007; Rodrigo E. Sanchez Brigido, *Groups, Rules and Legal Practice*, Springer, 2010 등 참고.

설적 결과가 발생할 수도 있을 것 같다. 결론적으로, 이 명제에서의 강조점이 나 지향점, 담고자 하는 가치 등에 주목하면서 관습의 본질과 범규성에 대한 대안적 설명을 구할 필요가 있다.⁴⁰⁾

3. 포함주의-배제주의 논쟁과 관습: 하트 이후의 지형

(1) 하트 이후 법실증주의의 분화

다시 법실증주의 논쟁으로 돌아가보자. ‘제재’와 ‘주권자의 명령’을 필수요소로 한 오스틴의 명령주의 범모델을 ‘규범의 내면화’에 의한 승인으로 대체한 하트의 규칙 모델 이후, 드워킨(Ronarl Dworkin)의 실증주의 공격을 계기로 그에 대응하면서 법실증주의 내부가 분화·발전하였다.⁴¹⁾ 이들은 기본적으로

39) 도덕규범이나 여타의 사회규범들과는 다르게 (실정)법규범이 갖고 있는 독특한 특징 중 하나는 원리적, 구조적인 면에서 체계성을 반드시 요한다는 점이다. 이런 점은 법의 본성(the nature of law)이나 법(체계)의 개념론 차원에서 여러 학자들에 의해 이론화되었다. 반면 자생적인 규범질서로서의 진성 관습 규범은 개별 사안마다 조정 문제 해결을 위한 대응책으로 각기 마련된 것으로서, 관습 규범들 사이의 종적 혹은 횡적 관계에서 논리적 위계나 체계적 정합성을 반드시 요하지 않는다. 그런 의미에서 평면적인, 일종의 열거적 규범조합체로도 표현해볼 수 있겠다. 이와 관련하여, 라즈는 도덕과 법을 대비시키면서 다음과 같이 주장한다. “법 혹은 우주나 다른 사회적 기관을 규율하는 규범들과는 달리, 도덕은 규칙들의 체계가 아니다.” Joseph Raz, “Incorporation by Law”, *Legal Theory*, 2004, p. 3.

40) 필자는 여기서 지적인 문제의식과 통찰을 발전시키되, 그것의 과도함은 감축하면서 관습의 본질에 대한 대안적 설명 이론들을 제시한다.(제4장)

41) 하트에 대한 드워킨의 공격 이후, 법실증주의 내부에서는 다양한 분파들이 형성되는데, 대표적으로 포용주의적/포함주의적 실증주의와 배제적 법실증주의 간의 논쟁이 주요하다. 가령, 포용적 법실증주의의 대표적 학자인 콜먼은 “내 버전의 포용적 법실증주의는 라즈의 배제적 법실증주의와 드워킨의 통합성으로서의 법에 대한 일관적이고 그럴듯한 라이벌”이라고 분명하게 밝힌다. Jules L. Coleman, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, 2001. p. 69. [물론, 윌드론의 ‘규범적 실증주의’나 캠벨의 ‘윤리적 실증주의’ 역시 상당히 유망한 입지를 점하고 있긴 하다. 윌드론의 규범적 실증주의에 대해서는 Jeremy Waldron (송성국 옮김), “규범적 (또는 윤리적) 실증주의”, 『법철학연구』, 2017 참고] 하지만 이 문제는 또 하나의 큰 연구주제로, 이 글의 논의범위를 넘어서기에 여기서는 ‘관습’ 문제를 매개로 한 크레이머-라즈 간의 논쟁에 범위를 한정하여 논한다.

하트의 기본 관점을 수용하고 핵심 개념들을 발전적으로 계승하면서도,⁴²⁾ 라즈(Joseph Raz)로 대표되는 배제적 실증주의자들과의 대립 안에서 도덕 원리의 법자격성과 법관의 활동에 대한 이론을 정교화한다. 구체적으로는, 하트의 승인율을 매개로 하여 법과 도덕의 관계에 대한 새로운 방식의 논쟁 양상이 펼쳐진다. ‘포용적 실증주의’ 혹은 ‘도덕합체주의(Incorporationism)’⁴³⁾는 도덕 원리나 기준들도 궁극적 승인율의 취지에 따라 법의 존재와 내용을 결정하는 가능 근거로 인정되거나 법의 일부분이 될 수 있다고 주장한다.⁴⁴⁾ 포용주의-배제주의 논쟁은 기본적으로 법과 도덕의 관계를 중심으로 한 것이지만, ‘법의 경계(the boundaries of law)’ 문제⁴⁵⁾라는 대 주제 안에서 포괄적으로 보면 관습의 법적 지위 문제도 실증주의 논쟁을 풍부하고 예리하게 하는 데 중요한 쟁점이 될 수 있다. 예컨대, 레프코위츠(David Lefkowitz)는 관습 규범이 권위적일 수 있다는 결론은 “크레이머(Matthew H. Kramer)의 비판에 반대하여 라즈를 옹호하기 위한 열쇠”⁴⁶⁾라고 주장한다. 결국 이 문제를 어떻게 풀어가느냐가 포스트 하

42) 하트적 착상을 계승한 후기 실증주의자들은 크게 세 가지 점에서 특징적이다. 우선 강제 또는 오스틴적 의미에서의 주권과 법 사이에 필연적 연관이 아닌 비본질적인 친연성을 인정한다. 또한 ‘관습의 승인(the recognition of custom)’과 ‘법 그 자체의 승인(the recognition of law itself)’이 본질적으로 다르지 않으며 상호 긴밀한 관련이 있다고 본다. 나아가, ‘승인’이라는 것을 규칙이라는 ‘규범 형식’을 넘어 하나의 ‘규범적 실천’이나 ‘과정’의 면에서 이해하려는 경향이 짙다.

43) 이 단락에서 ‘도덕합체주의’라는 용어는 심헌섭 교수의 번역을 따랐다. 심헌섭, “권위에 관하여-배제적 법실증주의에서 포용적 법실증주의으로”, 『분석과 비판의 법철학』, 법문사, 2003. 하지만 이 논변의 적용대상은 도덕원리에 한정되지 않기에, (가령, 외국법, 결사체 규약, 관습 등) 이후에는 문맥에 따라 ‘Incorporation(ism)’을 ‘포함주의’ ‘편입’ 등으로 옮긴다.

44) 이런 입장은 법과 도덕의 필연적 분리를 적극적으로 주장하기보다는, 오히려 법과 도덕은 ‘필연적으로 건련되어 있지 않다’고 말하는, 즉 법과 도덕의 필연적 건련성을 부정하는 ‘소극적 실증주의(negative positivism)’ 혹은 더욱 포괄적인 용어로는 ‘연성 법실증주의(soft positivism)’를 말한다.

45) Joseph Raz, “Incorporation by Law”, *Legal Theory*, 2004, pp. 14-17.

46) David Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, *Legal Theory* 11, 2005, p. 409. 레프코위치는 자신의 법철학적 입장을 바탕으로, 특히 관습국제법에서 논란되는 연대기적 오류를 해소하기 위해 하트적 접근을 발전시켜 역설의 해소를 도모한다. David Lefkowitz, “(Dis)solving the Chronological Paradox in Customary International Law: A Hartian Approach”, *Philosophy*

티안 담론 지형(Post-Hartian World)을 평가하는 중요한 한 척도가 될 수 있다.

(2) ‘편입 테제’ 논쟁과 관습에의 확장

포용적/포함적 실증주의자들은 법에 의한 편입(incorporation by law)을 주장하면서, 일정한 조건을 전제로 도덕 원리도 법이 될 수 있음을 역설한다.⁴⁷⁾ 이른바 ‘편입 테제(the incorporation thesis)’란 도덕적 기준이나 도덕 원리들은 그것이 법체계 안으로 그져 ‘편입(incorporation)’됨에 따라 법으로 전환되고, 법의 일부분이 될 수 있다는 견해를 말한다.⁴⁸⁾ 배제적 실증주의를 주창한 라즈는 “도덕을 배제시키는 법이라는 극적인 메타포를 포기”할 때라고 말하면서,⁴⁹⁾ “even Judges are humans”와 “morality applies anyway”⁵⁰⁾ 문구를 반복하면서 오히려 법관의 법적용에 있어 도덕 규범에의 의존이 편재함을 강조한다. 또한 라즈는 ‘편입 테제’를 포용적 실증주의자들이 법과 법적 기관(법창조기관과 법적용기관)과의 관련성에 따라 법자격성이 부여된다는 (라즈의 표현에 따르면) ‘단순한 견해(the simple view 혹은 simple minded-view)’⁵¹⁾를 비판하면서 제시된 대안으로 이해한다. 하지만 라즈는 둘 다 부적절한 주장이라고 반박한다. ‘단순한 견해’는 말 그대로 너무 단순하고, ‘편입 테제’는 수범자와 법원이 외국법이나 단체 규약들을 따르도록 지시하는 법(A)과 도덕의 편입(B)이라는 양자

Faculty Publications, 2008 참고.

47) Jules L. Coleman, “Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis”, *Legal Theory*, 1998; Jules L. Coleman, “Inclusive Legal Positivism”, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, 2001. 이 주제를 직접적으로 다루고 있는 국내 연구로는 이정훈, “법실증주의 승인율과 관행에 관한 연구”, 『법철학연구』, 2007.

48) Raz, “Incorporation by Law”, p. 1, p. 17.

49) Raz, “Incorporation by Law”, p. 9.

50) 두 문장은 배제적 법실증주의자인 라즈에 대한 부정확한 이해를 기초로 일반적으로 이뤄지는 흔한 오해들에 맞서는 반론의 중요한 기초를 이룬다. 그런데 충분한 보충 설명을 뒷받침하지 않은 채 문언상 한국어로 번역만 할 경우 자칫 본래 의미가 오해되거나 왜곡될 우려가 있어 부득이 일단 원문 그대로 기재하는 점에 대해 너른 양해를 부탁드립니다.

51) 라즈는 ‘단순한 견해’의 핵심 내용을 두 가지 명제로 요약한다. 법은 특정 기관과의 관련성(connection)에 의해 특징지어지며, 다음과 같은 두 방식으로 연관된다. Joseph Raz, “Incorporation by Law”, p. 16.

(AB) 사이를 구별하는 것을 설명해줄 이론적 자원이 부족하다고 지적한다. 특히 후자와 관련해서 보면, 편입 테제는 ‘도덕은 오직 편입되는 경우에만(only if) 적용된다’고 주장하는데, 실상은 도덕은 어떻게든지 적용되기에⁵²⁾ 편입 테제는 오히려 현실을 제대로 담지 못하는 것이다. 라즈의 결론은, 이른바 법을 편입한다는 것의 요지, 즉 효과는 도덕을 편입시키는 것이라기보다는 ‘법에 의한 도덕의 배제를 방지’하는 것임을 보여준다.⁵³⁾

그렇다면 이제 다시 본류로 돌아와 보자. 도덕적 기준이나 원리가 법의 일부분이 될 수 있는지 여부가 법과 법적 기관에 의한 ‘편입’이라는 창구를 통해서 결정되는지를 다루는 포용주의-배제주의 논쟁이나 편입 테제가 관습의 법적 지위와 법규성을 논하는 현재의 주제에 어떤 시사점과 자원을 제공할 수 있을까? 제정법을 중심에 두고 봤을 때, 도덕 원리는 한편으로는 관습 규범에 비해 적어도 사실성이나 객관성의 면에서는 더 큰 결함을 갖고 있다고 볼 수도 있고, 다른 한편으로는 많은 부분에서 도덕 원리와 유사성을 공유한다고 볼 수도 있다. 즉 좁은 의미에서 비(非)법적 규범이라는 공통점과 규범 자체의 특질에서의 차이점을 적절히 고려한다면, 편입 테제를 관습 문제로 확장 적용해보는 시도도 가능할 것이다. 이는 관습의 법규성을 규정함에 있어 공적인 법기관의 제도적 권위에 의탁하는 문제-제2장 제1절에서 논한 고전적 법실증주의자들의 해법이나 제3장에서 다루게 될 역설 현상과도 연결되는-와도 이론적으로 맞닿아 있다. 이렇듯, 논변의 확장적 시도를 통해 포용주의(incorporationism)의 부적절성을 논증하고 배제적 법실증주의를 옹호하는데 관습법의 문제를 활용한 예가 있다.

(3) 이른바 ‘관습 유비 논변’과 ‘자유-부유 논변’

이하에서는 관습법의 권위에 대한 라즈의 논변을 포함주의적 입장에서 반박하는 크레이머의 논전을 중심으로, 관습의 본질과 법적 지위를 둘러싼 최신의 또 다른 법철학 논쟁을 살펴보자.

52) 원문은 “morality applies anyway.” Raz, “Incorporation by Law”, p. 17.

53) Raz, “Incorporation by Law”, p. 17.

포함주의(incorporationism)를 이끄는 대표적인 학자인 크레이머(Matthew H. Kramer)는 그의 저서 *Where Law and Morality Meet*(2004)⁵⁴⁾에서 포함주의와 배제적 실증주의 간의 논쟁 해결을 연구 목표 중 하나로 정했다. 주지하듯이, 포함주의와 배제주의 둘 다 판사가 해결하기 어려운 사안(hard case)을 해결할 때 도덕 원리가 그들에게 구속력 있는 이유를 제공한다는 점에는 동의한다. 다만, 그 경우 법관의 그러한 관여 행위를 법이론적으로 어떻게 기술하는지, 그 연장선상에서 도덕 원리의 법적 지위를 어떻게 규정하는지에 있어 의견불일치가 발생하는 것이다. 포함주의자들은 법관이 해당 법체계 안에 이미 존재하는 법을 적용하는 것이라고 주장하는 반면, 배제주의자들은 그 경우 법관은 마치 입법자처럼 새로운 법을 창조하는 것이라고 기술한다. 상반되는 이런 설명의 타당성 판정은 결국 해당 법체계의 승인율이 도덕 포함적인지 여부에 상당히 의존한다. 만약 승인율이 포함적이라면 판사는 있는 법을 적용하는 것이고, 그렇지 않다면 판사는 그 사건을 권위적으로 해결하고자 법창조 행위를 하는 것이다. 바로 이 지점에서 두 입장이 대립한다. 따라서 법관이 종종 도덕 원리를 분쟁 해결의 구속력 있는 이유로 다룬다는 점을 지적하는 것만으로는 배제주의와 포용주의 간의 대립과 경쟁을 해결할 수 없는 것이다. 그렇다면 결국 ① 도덕 원리 자체의 속성에 다시금 초점을 맞추는 원론적인 방법(적극적 방식)이나, 혹은 ② 성문법규는 아니지만, 법체계 안에서 가능한 범원으로 인정받은 다른 법규범들과 도덕 원리가 공유하는 유사성을 중심으로 한 유비 논증(소극적 방식)이 가능할 것이다.

연성 실증주의자인 크레이머는 두 번째 전략으로, 관습과의 유비를 통해 배제주의에 대항하고 포함주의를 옹호한다.⁵⁵⁾ (이를 ‘관습 유비 논변’이라고 불러보자.) 크레이머의 관습 유비 논변은, ① 관습 규범과 도덕 원리는 ‘자유롭게 부유

54) Matthew H. Kramer, *Where Law and Morality Meet*, Oxford University Press, 2004.

55) 크레이머는 필자가 구분한 두 방식의 논증 전략을 모두 취하는데, 결론적으로는 도덕 원리가 관습 규범과 공유하는 유사성보다는, 도덕 원리 자체의 속성에 초점을 맞추므로써 ‘배제주의-포용주의 논쟁’은 포함주의 쪽으로 해결될 수 있다고 주장한다. Kramer, *Where Law and Morality Meet*; Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 406.

한다(free-floating, 이하 '자유-부유'로 축약함)'는 점에 대한 입증과(포함주의적 승인율과 함께), ② 배제주의자인 라즈 법철학⁵⁶⁾의 명백한 비밀관성을 지적하는 두 부분으로 구성된다. 크레이머의 설명에 따르면, 라즈는 관습을 가능한 법원(possible source of law)으로 보증하지만 도덕 원리에는 그런 지위를 부정하는데 그 논거가 일관되지 않다는 것이다.⁵⁷⁾ 즉 라즈가 관습을 법의 가능한 원천으로 채택하는 한, 도덕 원리인 '올바름(correctness)'에도 동등한 법적 지위를 부여해야 한다는 것이다. 이런 주장을 뒷받침하기 위해 크레이머는 세 단계로 논증한다. 우선 ① 법공직자들이 관습 규범에 구속력을 인정하는 이유를 밝히고, ② 관습 규범과 달리 외국법이나 단체 규약은 법원으로 인정되지 못하는 이유와의 차이점을 논하고, 궁극적으로 ③ 도덕 규범을 포함하여 우리가 법이라고 분류하는 규범들의 공통된 특질이 무엇지를 밝힌다. 차례로 살펴보자.

우선, 크레이머에 따르면 공직자들이 관습 규범에 구속력을 인정하는 이유는 어느 정도는 그들이 외국법이나 결사체 규약에 구속력을 인정하는 이유와 유사하다. 즉, "L 법역의 공직자가 관습 규범을 원용한다는 것은 곧 그 규범이 추출되어 나오도록 한 실천(practice)에 대한 응분의 고려(due regard)를 베푸는 것을 뜻한다."⁵⁸⁾ 하지만 관습 규범과 외국법(혹은 결사체 규약) 사이의 비유사성은 유사성보다 더 큰 의미를 갖는다. 외국법이나 결사체의 성문화된 규약은 "권위 있는 위치를 점한 사람들의 결정으로부터 나오며", "권위 있는 지위에 있는 사람들이 수행하는 표준화된 절차를 거친 의식적인 행위에 의해 변경되기도" 한다. 반면에 관습적 계율(customary precept)은 "정형화된 절차를 통한 의식적이고 돌발적인 행위로 변경되지 않"으며, "명백히 권위 있는 경로를 통해서 발행(issue)되는 것도 아니다. 그보다는, 전형적으로 아무런 공식적인 위

56) 법의 본성에 관한 라즈의 대표적인 논문으로는, Joseph Raz (권경휘 옮김), "권위, 법 그리고 도덕", 『법철학연구』, 2009; Joseph Raz (권경휘 옮김), "법의 본성에 관한 문제", 『법철학연구』, 2007 등 참고. 또한 라즈 법이론 전반의 토대를 이루는 권위론에 대한 국내 연구로는, 박준석, "권위의 두 개념", 『법철학연구』, 2007; 박준석, "조셉 라즈(Joseph Raz)의 권위론에 대한 비판적 고찰", 『법철학연구』, 2007 등 참고.

57) Lefkowitz, "Customary Law and the Case for Incorporationism", p. 408.

58) Kramer, *Where Law and Morality Meet*, pp. 39-40.

계나 권위적인 선포도 없이 이루어지는 산발적인 실천(diffuse practice) 속에 내재한다.”⁵⁹⁾ 즉, 관습적 계율의 내용은 ① 그 누구의 효과적인 통제에 속해 있지 않으며, ② 중앙조직화된 결정이 아닌 산발적 행동양식에 기인하기 때문에, ③ 그러한 계율을 특정 법역 안에서 적용한다는 것은 그 법역이 가진 법규범의 집적체(assemblage)에 이를 편입시키는 것으로 이해해야 한다는 것이다.⁶⁰⁾ 크레이머는 바로 이런 점을 들어 관습 규범의 속성을 ‘자유-부유’한 것으로 설명한다. 그런데 이런 특성은 한편으로는 외국법이나 단체규약과의 중요한 차이점이 되지만, 다른 한편으로는 도덕 규범과의 유사성으로 볼 수도 있다. 즉 ‘자유-부유’를 특질로 하는 관습 규범이 ‘편입’에 의해 법의 일부분이 된다면, 같은 논리로 도덕 규범 역시도 똑같은 법적 지위를 부여받아야 한다는 주장이 가능해지는 것이다.

그런데, 레프코위츠(David Lefkowitz)는 바로 이 지점에서 크레이머의 이른바 ‘자유-부유 논변’의 부적절함을 지적한다. 레프코위츠에 따르면, 관습 규범이 ‘자유-부유’한 상태에 있기 때문에 (편입에 의해) 법의 원천이 될 수 있는 것이 아니라, 관습 규범은 권위적(authoritative)일 수 있기 때문에 법의 일부가 될 수 있고 도덕 규범은 그렇지 못하다고 반론한다. 또한 법의 본성에 관한 라즈의 개념관 안에 그 어떤 것도 ‘자유-부유 상태에 있음(being free-floating)’이 법으로 편입될 자격이 되는 필요조건임을 함축하지 않는다고 주장하면서, 결론적으로 배제주의에 대항하고 포함주의를 옹호하기 위한 크레이머의 논증 전략은 문제가 있다고 재반박하면서 관습법의 권위에 대한 라즈의 설명을 발전시킨다.⁶¹⁾

그렇다면, 크레이머에 대한 레프코위츠의 이러한 반론은 적절한 것인가? 생각건대, 레프코위츠의 주장은 일부는 맞지만 일부는 부정확한 면이 있는 것 같다. 일례로, 크레이머의 텍스트를 꼼꼼히 독해해보면, 크레이머가 ‘관습 유비 논변’을 통해 도덕 규범의 법적 편입과 법규성을 주장하는 가장 중요한 논거는 그것이 ‘자유-부유’한 상태에 있다는 속성 때문이라기보다는 그것이 법공직자들의 법적 결정에 제공하는 ‘정당화 기능’에 있음을 알 수 있다. 즉, 크레이머는

59) Kramer, *Where Law and Morality Meet*, p. 40.

60) Kramer, *Where Law and Morality Meet*, pp. 40-41.

61) Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 405.

‘자유-부유 논변’에서 한 걸음 더 나아가 추가 논거를 제시한다. 그는 “법공직자들의 권위적 발화를 향도하는 어떤 규범에 법의 지위를 부여하기에는 자유-부유 상태에 있는 것만으로는 충분치 않다.”고 하면서, 일례로 문법 규칙과 같은 것은 법관의 권위적 발화를 향도하지만 그것이 법규범은 아니라는 점을 지적한다. 결론적으로, 크레이머는 “법률, 법리, 행정법규, 관습 규범과 더불어 도덕 규범이나 여타 규준들이 법이라고 분류될 수 있는 가장 명백한 특질”은 그것이 “결정을 정당화하는 규준들(decision-justifying standards)”이기 때문⁶²⁾이라고 역설한다. 그렇다면, 크레이머의 라즈 비판에 대한 레코프위츠의 재반박은 과연 적절하고 성공적인가? 그렇지는 않은 것 같다. 요컨대, 레코프위츠는 “크레이머의 비판에 대항하고 라즈를 옹호하기 위한 핵심은 관습 규범은 권위적일 수 있다”⁶³⁾고 주장하면서 크레이머의 라즈 비판을 재반박하지만, 이는 크레이머의 ‘관습-유비 논변’과 ‘자유-부유 논변’에서 강조점이 어디에 있는지에 대한 약간의 오해에 기반하거나,⁶⁴⁾ 라즈의 배제주의를 옹호하는 과정에서 부당하게 왜곡하는 우를 범했다고 볼 수도 있을 것 같다.⁶⁵⁾

4. ‘법의 충돌’인가, ‘법리학의 충돌’인가

이상으로 영미 법실증주의 진영을 중심으로 관습의 법적 지위와 법규성을 둘러싼 주요한 법철학 논쟁과 변천사를 크게 세 시기-고전적 법실증주의, 현대

62) Kramer, *Where Law and Morality Meet*, p. 41.

63) Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 409.

64) 하지만 대상 논문에서 레코프위츠는 정작 크레이머가 라즈의 입장을 오해했다고 비판한다. 자세한 사항은, Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 416. 이하 참고.

65) 물론, 레코프위츠가 라즈의 견해를 무조건적으로 수용하는 것은 아니며 적절히 취사선택하여 변증적으로 발전시킨다. 가령, 레코프위츠는 “우리는 모든 법의 모든 측면은 어떤 행위자의 의도의 산물이라는 라즈의 주장을 따를 필요는 없다.”고 주장한다. Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 413. 그리고 관습 규범이 권위적일 수 있음에 대한 실질적인 논변과 분석을 제시한다. 이는 관습의 법규성 논의에도 많은 시사점을 제공하지만, 본 장의 1차 목표는 관습의 법규성이란 주제가 포용적 법실증주의와 배제적 법실증주의 논쟁 안에서도 중요하게 다뤄진다는 점을 보여주는 데 있기에 보다 상세한 고찰은 뒤로 미룬다.

법실증주의, 후기 실증주의-로 나누어 살펴보았다. 관습의 법규성과 법적 지위 문제는 법의 본성을 궁구하는 법철학에서 중요한 문제 소재가 될 뿐만 아니라, 실제로 법실증주의 진영에서는 그들의 법개념론 안에서 반드시 풀어야 할 난제 중 하나라고 볼 수 있다. 가령, 법의 본질과 규범성의 근거를 ‘제재’로 이해하는(‘제재 테제’) 오스틴의 명령주의 법모델에서 가능한 선택지는 ① ‘묵시적 명령’이나 ② ‘주권자의 각료(minister)’로서 판사라는 관념을 통한 환원주의적 분석이다. 반면, 반(反)-오스틴적 대안으로 ‘규범의 내면화’를 법규성의 근거로 삼고 궁극적 승인율의 수용(‘수용 테제’)을 통한 ‘내면화의 함수’로 법을 설명한 하트의 법모델 역시 일원주의적 승인율을 통한 약한 환원주의라는 비판이 가능하다. 하트 이후에, 하드 케이스에서 도덕 원리의 법적 위상을 다투는 포함주의와 배제적 법실증주의 간의 논쟁에서도 ‘편입 테제’의 확장과 ‘관습 유비 논변’은 도덕 원리의 법자격을 논증하기 위한 유용한 통로의 역할을 한다.

이 장에서 필자는 “법철학에서 관습이 왜 중요한가?”라는 물음에 대해 실제 법철학 이론사 안에서 이 문제의 중요성과 역할을 보여줌으로써 간접적으로나마 일부 답변을 한 것 같다. 다만 본 장을 맺으면서 우리는 한 가지 질문을 던질 필요가 있겠다. 관습의 법적 지위 문제는 결국 ‘법의 충돌(conflicts of law)’, 즉 법규범들 간의 갈등과 긴장의 문제인가, 아니면 ‘법리학의 충돌(conflicts of jurisprudence)’⁶⁶⁾인가? 이 장에서는 후자의 관점에서, 즉 법실증주의(혹은 비실증주의)라는 법철학 이론 간 논쟁이라는 창(窓)을 통해 이 주제를 살펴본 셈이다. 하지만 이러한 우회로를 통한 답에 만족하기에는, 관습이나 관습법이 갖는 특유성과 가치가 충분히 조명되지 못할 뿐 아니라 법체계 안에서 관습 규범의 위상에 대한 적합하고 풍부한 답을 얻기 어렵다. 그렇다면 방법론적 혁신이 필요하다. 기존의 이론 틀과 특정한 법리학적 입장의 렌즈를 벗어던지고,⁶⁷⁾ 하나의 특유한 규범적 질서로서 관습 그 자체의 본질에 대한 철학적 탐구에서 출발

66) 이 표현은, Schauer, “The Jurisprudence of Custom”, p. 534.

67) 참고로, 결론은 조금 다르지만, 국제관습법 문제와 관련하여 법리학(jurisprudence)의 역할에 대한 회의론을 제기하는 글로는, Steven Walt, “Why Jurisprudence doesn't Matter for Customary International Law”, *William & Mary Law Review*, 2013.

하여 법체계 안에서 관습법의 위상과 법규성을 규명하는 목적지로 나아가 보자. 다만, 필자의 이러한 방법론적 전환을 정당화하면서 동시에 제2장에서의 법철학 이론사적 고찰과의 가교를 위해 우선은 기존의 법이론적 담론 안에서 문제시될 수 있는 일종의 병리 현상과 역설 문제 등을 검토해보기로 한다.

III. ‘관습 없는 관습법’과 ‘관습법의 역설’

본 장에서는 관습 혹은 관습법을 사유의 중심에 놓고, 관습법의 법규성을 옹호하는 입장에 대한 근본적이고도 치명적인 반론이 될 수 있는 일종의 병리 현상, 즉 ‘관습 없는 관습법’⁶⁸⁾과 ‘관습법의 역설’ 문제를 다룬다. 본고 제2장이 “무엇이 관습을 ‘법’으로 만드는가?”라는 물음에 대해 법철학 논쟁사를 중심으로 논하였다면, 제3장에서는 “무엇이 관습법을 ‘문제적’으로 만드는가?”라는 문제의식을 중심에 놓는다. 특히 이 주제는 “법원으로서의 관습(Custom as a Source of Law)” 테제와 법체계 안에서 제도적 권위를 가진 법적 기관, 그 중에서도 특히 사법부의 필수적인 관여와 역할에 대한 고려가 큰 비중을 차지한다.

68) 국제법영역에서 국가실행(state practice)의 과중한 역할이나 기능을 강조하면서 ‘관습 없는 관습법’이라는 표현을 쓰기도 한다. Niels Petersen, “Customary Law Without Custom? Rules, Principles, and the Role of State Practice in International Norm Creation”, *American University of International Law Review*, 2008을 참고할 것. 또 다른 한편으로는, 결은 조금 다르지만, 최근 국내 법사학계를 중심으로 논란이 되었던 “동아시아에서는 진정한 의미에서의 관습법이 존재하지 않았다”는 극단적인 회의주의적 문제 제기와 그에 대한 대응의 과정에서 거론된 현상들, 그리고 일제식민시대 관습의 존부 문제와 관련한 부정적 견해에 대해서도 ‘관습 없는 관습법’이란 명명이 가능할 것 같다. 다만 여기서는, 이러한 모든 현상들을 포괄하고 총칭하는 차원에서 형용 모순적인 철학적 표현으로 사용한다. 한국법사학회의 관습법 존부 논쟁과 관련해서는, 심희기, “일제강점기 초기 ‘식민지관습법’의 형성”, 『법사학연구』, 2003; 심희기, “동아시아 전통사회의 관습법 개념에 대한 비판적 검토-일본식민지 당국에 의한 관습조사를 중심으로”, 『법사학연구』, 2012; 정궁식, “조선민사령과 한국 근대 민사법”, 『동북아법연구』, 2017 등 참고.

1. ‘관습 없는 관습법’?

전형적인 법률적 사고 방식 안에서 사실로서의 ‘관습’과 규범으로서 ‘관습법’을 개념적으로나 실천적으로 엄밀히 구별하려는 입장이 법조계에선 지배적이다. 제2장에서 살펴보았듯이, 특히 관습법의 법적 지위를 논함에 있어서 제정법의 논리를 그대로 차용하려는 입장에서 채택하기 손쉬운 답변 중 하나는 ‘관습법의 본질은 법관법(judge-made law)’이라는 회의주의적 답이다. 대표적으로, 코먼로에 대한 경멸과 관습법에 대한 회의적 시각⁶⁹⁾을 갖고 있었던 벤담이 그러했다. 벤담의 결론은, 법원의 활동을 통한 관습의 법제화(legalization)는 매우 불만족스럽고 문제적이며, 보다 곧바른 경로로서 성문법규가 관습을 직접 인수해야 한다고 주장한다. 그리고 이런 방식이 더욱 바람직할 뿐만 아니라 관습 그 자체를 더욱 존중하는 것이라고 역설한다.⁷⁰⁾⁷¹⁾ 이러한 벤담식의 생각 근처에는 한편으로는 사법부나 그들의 활동에 대한 모종의 불신과 입법에 대한 신뢰가 놓여 있다고 볼 수 있다.

필자가 ‘관습 없는 관습법’이라고 이름 붙인 현상은 관습법의 본질은 법관법이라는 주장의 극단적 양상을 보여준다. 관습법에 대한 전통적 견해들은 관습

69) 다만 오해하면 안 될 것은, 벤담이 관습법의 가치를 폄하하거나 관습법을 부인한 것은 아니었다는 점이다. 벤담은 코먼로에 대해서는 경멸의 시선을 보냈지만, 관습법의 고유한 가치는 긍정했으며 다만 실정법으로서 자격을 인정하기에는 불완전함이 있기에 입법을 통한 보완을 주장했다. 이런 입장을 적극적으로 계승하고 있는 현대 법철학자로는, Jeremy Waldron, “Custom Redeemed By Statute”, *Current legal problems*, Vol. 51, 1998.

70) Waldron, “Custom Redeemed By Statute”, p. 100.

71) 그런데 흥미로운 것은, ‘관습 규범의 성문화’ 혹은 ‘제정법에 의한 관습 보충’ 등의 기획이 벤담의 생각과 정반대의 효과를 낳았다는 실증적 주장이 한국 법사학계에선 지배적이다. 일례로, “조선민사령의 제정 취지는 한국의 관습을 존중하는 것이었지만, 실제로는 일본제국이 식민지 조선을 효과적으로 통치하려는 것이었다. 이는 조선인에 대해 동화와 차별을 구현한 법정책이었다.” 정궁식, “조선민사령과 한국 근대 민사법”, 『동북아법연구』, 2017; 심희기, “일제강점기 초기 ‘식민지관습법’의 형성”, 『법사학연구』, 2003 등을 참고할 것. 이는 관습에 관한 일반 이론이 보편성 차원에서 갖는 한계나 특수성, 그리고 국지성과 역사성의 측면을 잘 보여준다.

법의 성립 및 효력요건을 객관적/사실적 요소인 ‘관습 혹은 관행의 존재’와 주관적/규범적 요소인 ‘법적 확신’의 결합으로 설명한다.⁷²⁾ 이런 맥락에서 ‘관습 없는 관습법’이란 관습법의 객관적 성립요건에 해당하는 관습이나 관행 자체가 사실상 객관적으로 존재하지 않음에도 불구하고 판사의 사법 활동을 통해서 그것이 법이라 확신을 획득하여 관습법으로 탈바꿈한다는 주장이다. 이러한 가설에 따르면, 관습법이란 판사가 만드는 법, 즉 법관법의 다른 이름에 불과하다는 비난도 가능해진다. 이러한 점은 제2장에서도 살펴보았듯이, 고전적 법실증주의자인 벤담의 견해에서도 발견할 수 있었다.

흥미로운 것은, 필자가 명명한 ‘관습 없는 관습법’ 현상은 비단 코먼로 법체계를 배경으로 한 서구에 특유한 법현상은 아니라는 점이다. 우리 조선시대 식민지 관습법에서도 실증 사례를 발견할 수 있다. 일례로, 국내 선행 연구들은 “상속회복청구권은 20년이 경과하면 시효로 인하여 소멸한다.”고 한 조선고등법원의 관습법은 ‘관제(官制)된 ‘관습법’이며, ‘조리’의 원리를 관습의 이름을 빌려 창조하여 왜곡된 관습법으로 평가”해 왔다고 한다. 결론적으로, 당시 조선에서는 그러한 내용의 관습이 존재하지 않았음에도 불구하고,⁷³⁾ 조선고등법원의 판결을 통해 관습의 존재가 창출되고 현재까지도 대법원에서 관습법으로 법적 효력을 인정받고 있다.⁷⁴⁾ 또 다른 한편으로, 국내법질서를 넘어 국

72) 필자는 관습법 성립요건의 이원적 구도에 매우 회의적이다. 이는 부정확하고 비현실적일 뿐 아니라 실천적 측면에서도 많은 문제와 부작용을 낳는다. 따라서 관습법의 문제를 근본적으로, 제대로 풀어가기 위해서는 이러한 이분법에 대한 해체와 재구성, 그리고 대안적 설명이 필요하다.

73) 실천의 장에서 ‘관습 없는 관습법’ 문제를 해결하기 위한 제도적 장치로 실제 그러한 관습이 존재했는지에 관한 실증 조사를 통해 ‘관습 있음’을 객관적으로 증명하는 방법이 가능하다. 이런 해법은 실제 우리 역사상 존재했는데, 그 맥락을 초월하여 방법론적 차원에서만 참조하여 제도설계의 차원에서 새롭게 도입해볼 수도 있겠다. 참고로, 일제 강점기 관습조사의 문제를 다룬 글로, 이승일, “일제의 관습조사와 전국적 관습의 확립과정 연구-『관습조사보고서』의 편찬을 중심으로”, 『대동문화연구』, 2009.

74) 손경찬, “상속회복청구권의 시효에 관한 관습법 실증”, 『법사학연구』, 2019 참고. 다만, 이 사안의 경우에는 한 가지 쟁점이 추가적으로 더 존재한다. 즉, 사법부에 의한 ‘관습 없는 관습법’의 창설뿐만 아니라, 다른 한편으로는 일제총독부가 주도한 식민정책의 일환으로 관습법의 형성과 왜곡이 일어난 것이다. 말하자면, 두 개 국가기관의 공조로 ‘관습 없는 관습법’ 현상이 의도적이고 체계적으로 발생했다는 평

제법질서의 차원에서도 이러한 문제는 발견된다. 국제관습법의 경우에 ‘관습 없는 관습법’ 현상은 결국 강대국의 힘의 논리로 환원된다는 현실주의 국제관계이론과도 연결될 수도 있다.

‘관습 없는 관습법’ 현상은 일차적으로는 일반 시민들의 자발적인 규범적 실천을 통해 형성되는 관습법이 갖는 민중성, 자생성 등의 특유성과 그에 수반되는 유연성이나 개방성 같은 고유한 장점을 몰각시키는 우를 범할 수도 있다. 나아가, 이러한 병리 현상은 사법적 실천의 장에서도 중요한 법철학적 문제를 발생시킨다. 비교하여 말하자면, 해결하기 어려운 사안을 해결하는 과정에서 예외적이고 불가피하게 이뤄지는 판사의 사법 재량은 정치적으로 정당화될 수도 있지만, ‘관습 없는 관습법’을 창설하는 판사의 사법적 입법행위는 불가피하다고 보기도 어렵고 최소한의 객관적 토대조차 상실하고 있다는 점에서 더욱 심각한 결함을 내포한다고 볼 수 있다. 이 문제는 이어서 검토할 ‘관습법의 역설’과도 연결된다.

2. 관습법의 역설: 두 차원

(1) 민중법에서 엘리트주의적 법원으로서의 전락

입법부의 의도적인 입법 행위에 의해 하향식(top-down)으로 정립되는 성문법규와는 달리, 공동체 구성원들에 의해 자생적으로 형성된 규범적 질서가 상향식(bottom-up)으로 제도화된 관습법은 여러 면에서 특별함을 갖는다.⁷⁵⁾ 대표적으로 자생성, 민중성, (직접)민주성, 개방성과 유연성 등이 그러하다.⁷⁶⁾ 그

가도 가능하다. 이렇듯, 조선고등법원에서 인정된 소위 관습법이 과연 서구식 근대 법이론에서 말하는 관습법에 해당한다고 볼 수 있는지에 대해서는 법사학계의 논쟁이 있다.

75) 관습법의 이런 특징을 ‘비-계약적 메커니즘’으로 설명할 수도 있다. 예컨대, 경제학자인 파리는 경제학적 관점에서 관습법을 분석하면서, 관습법을 사회 규범과 유사시키면서 ‘비-계약적 메커니즘’을 말한다. Francesco Paris, “Spontaneous Emergence of Law: Customary Law”, *Encyclopedia of Law & Economics*, 2000, p. 606.

76) 그런데 관습법의 법원성 문제가 가장 첨예하게 문제시되는 국제법영역에서는 도구적 관점에 입각하여 관습국제법의 세 가지 특징으로 보편성, 불문성, 비협상성(non-negotiated character)을 꼽기도 한다. 이런 설명은 현실주의 입장과 통한다.

중에서도 민중성과 (직접)민주성은 불문 형식의 관습법이 갖는 약점에 대한 비판에 대응하고 결점을 상쇄할 만한 중요한 강점이다. 그런데, 만약 관습법의 본질이 법관법이라면, 관습법은 결국 소수의 사법 엘리트들에 의해 창설된 산물로 ‘엘리트주의(elitism)’의 표상이 되는 셈이다.⁷⁷⁾ 바로 여기서 ‘관습법의 역설’ 현상이 발생한다. 관습 혹은 관습법에 대한 가장 기본적인 발상은 그것이 국가기관의 개입 없이 평범한 일반 민중들의 자발적인 행위 수렴에서부터 시작된다는 것이며, 따라서 가장 직접적인 민주주의적 함의를 내포한다. 그런데 그것이 법체계 안에서 법원을 통해 법적 지위를 부여받아 ‘관습법’이라는 이름으로 격상되는 순간, 역설적으로 그것이 갖는 본질과 고유한 강점이 상실될 뿐 아니라 정반대 방향으로 극단화된다는 것이다. 민중적 혹은 민주적이라는 특징은 허울 좋은 가면이나 허구가 되고, 실체는 ‘관계’ 법원(法源)이자 엘리트주의적 법작용의 유력한 통로가 되는 셈이다. 가장 민주적인 법원인 관습이 오히려 민주적 정당성을 부여받은 입법부에 의해 정립된 제정법보다 더 비민주적이며, 나아가 엘리트주의적 법원(法源)으로 전락한다면 그것이야말로 가장 역설적인 법현상으로 평가받을 수 있을 것이다.

그렇다면, 이러한 비민주적 역설 현상이 발생하고 유지될 수 있는 배경이나 조건은 무엇일까? 생각건대, 필자가 ‘관습법의 역설’로 명명한 이 현상은 관습법의 주관적 성립요건인 ‘법적 확신’이라는 개념적 창구를 통해 이론적으로 정당화될 수 있어 큰 도전 없이 유지될 수 있다. 결론적으로, 극단적인 엘리트주의적 법원으로서의 전락을 의미하는 ‘관습법의 역설 현상’은 결국 ‘법적 확신’의

Laurence R. Helfer & Ingrid B. Wuerth, “Customary International Law: An Instrument Choice Perspective”, *Michigan Journal of International Law*, 2016, pp. 568-580. 참고.

77) 여기서의 비판의 핵심은 ‘관습법의 본질이 법관법’이라는 주장에 있다. 즉 별개의 법원(法源)으로 인정되에도 불구하고 관습의 특수성이 제거되고 법관법으로 환원되는 현상을 지적한 것이다. 유의할 점은, 이런 주장이 법원으로서 법관법의 부적절함을 전제하거나 수반하는 것은 아니라는 것이다. 국내 법철학계에서 법원론과 법학방법론의 관점에서 법관법에 대한 깊이 있는 연구로는, 이계일, “법관법의 대상영역과 규범적 힘에 관한 연구”, 『법학연구』, 2016; 이계일, “판결의 법산출성을 강조하는 법이론의 입장에서 본 법관법”, 『법철학연구』, 2016; 이계일, “법관법의 법원성에 대한 유형적 탐구”, 『법철학연구』, 2016; 이계일, “법관법 변경의 효력범위 설정에 대한 비판적 탐구”, 『법철학연구』, 2021 등 참고.

모호성과 비실증성⁷⁸⁾으로 인한 ‘개념적 역설’ 혹은 ‘연대기적 역설’ 문제와도 맞닿아 있다. 이 문제는 특히 국제관습법에서 중요한 쟁점으로 다뤄진다.

(2) 선결문제의 오류와 순환논법: ‘연대기적 역설’

주로 국제법영역을 중심으로 국제관습법의 법원성을 둘러싼 주요한 비판 중 하나는 그것이 ‘선결 문제의 오류(question-begging)’⁷⁹⁾를 범한다는 것이다. 즉 답해야 할 물음을 전제함으로써 일종의 논리적 모순을 발생시킨다는 것이다.⁸⁰⁾ 이 문제는 관습법의 주관적 성립요건인 ‘법적 확신(opinio juris)’ 문제로 귀결되는데, 법적 확신의 존재와 확인 및 증명을 둘러싼 이론적·실천적 어려움으로부터 연원한다. 문제는, 법적 확신을 인식하고 그 존재를 객관적으로 증명할 방법론이 개발되어 있지 않다는 것이다. 그 결과, 객관적 성립요건에 해당하는 관행이나 관습의 존재로부터 간접적으로 추정하기도 한다. 그런데 이런 접근은 두 가지 점에서 문제를 야기한다. 첫째, 논리적으로 순환논법의 오류를 범한다. ‘법적 확신’의 존재를 확인하기 위해서는 사람들이 오랫동안 준수해왔다는 관습 규범의 존재를 통해 단서를 찾아 간접적으로 추단하여 증명할 수밖에 없기에 순환논법이 된다. 그리고 현실적으로는 결국 기준에 ‘이미’ 존재하고 있는 어떤 법규범을 미리 전제하고 그것에 따른 확신의 존재를 ‘법적 확신’으로 의제하는 결과에 이를 수도 있다. 둘째로, 현실적으로 볼 때 특정한 관행적 실천이 있게 되는 이유는 무척이나 다양할 수 있기 때문이다. 즉 어떤

78) “법적 확신도 실증적으로 확인하기 쉽지 않은 요건이다. 각국 정부의 외교문서, 국제기구에서의 결의, 민간단체의 지지, 국내법원의 판례 등 다양한 형식의 의사표시와, 나아가 침묵이나 묵시적 동의 등에서 법적 확신을 추출해 내고 그를 평가하는 기법이 존재하지 않는다.” 김화진, 『국제법이란』, 박영사, 2017, 26면.

79) ‘선결문제의 오류(Begging the Question)’란 증명을 요하는 사항을 전제 속에 채워하는 논리적 오류로, 전제 속에 결론과 같은 뜻의 말을 쓰고 있는 것을 말한다. ‘논점 선취의 오류’라고도 한다.

80) 국제관습법의 성립요건 중 ‘법적 확신’이란 중요하지 않으며, 법적 확신에 대한 요구는 그 자체 모순된 주장이라는 비판이 있다. 왜냐하면 법적 확신이란 국가가 특정한 행동을 하기 이전에 “이미” 어떤 법규칙이 존재할 것을 전제로 하는 개념인데, 법적 확신의 성립 이전에 법은 존재하지 않게 되기에 결론적으로 국제관습법의 성립요구는 논리적 모순이라는 비판이다. 정인섭, 『신국제법강의: 이론과 사례』, 제10판, 박영사, 2020, 38-39면.

관행적 실천이 그에 대한 법적 확신으로부터가 아닌 다른 이유에서 비롯되고 지속되고 있을 수도 있는데, 그런 경우라면 그러한 관행이나 관습의 존재를 관습법의 토대로 보기는 어려울 것이기 때문이다.⁸¹⁾ 요컨대, 관습법의 존재를 판정하기 위해서는 법적 확신에 대한 인식과 확인이 선행되어야 하는데, 객관적인 인식 수단이 마련되어 있지 않은 한 ‘법적 확신’이란 일종의 이론적 수사나 허구에 불과할 수밖에 없게 된다. 이러한 선결문제의 오류는 특히 국제관습법과 관련하여 관습법의 개념이 문제시된다.⁸²⁾ 국제관습법에서는 이를 ‘연대기적 역설(Chronological Paradox)’로도 불리는데,⁸³⁾ 관련 의문의 핵심은 법적 의무의 근원이 되는 법이 형성되기 전에 도대체 어떻게 그 법적 의무에 대한 확신이 존재할 수 있느냐는 것이다.⁸⁴⁾ ‘연대기적 역설’은 “특정 관습법 규범이 이미 존재하고 자신을 구속하고 있다는 국가들의 잘못된 믿음에 의해서만 그 관습법이 형성될 수 있다”는 법적 확신 개념의 역설적 성격을 말해준다는 설명도 있다.⁸⁵⁾

3. 두 현상의 이론적 · 실천적 출구와 역설의 해소

그런데, ‘관습 없는 관습법’ 현상과 ‘관습법의 역설’은 정말로 극복의 대상으로서 문제적인 것일까? 만약 그러하다면, 이러한 문제를 해결하기 위한 방안은

81) 박준석, 『법사상, 생각할 의무에 대하여』, 아카넷, 2015, 239면, 각주 31.

82) 예컨대 Anthony D'amato, "New Approaches to Customary International Law", *The American Journal of International Law*, 2011, pp. 166-167.; John Tasioulas, "Customary International Law and the Quest for Global Justice", Amanda Perreau-Saussine & James Bernard Murphy (ed.), *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007, p. 320. 이하 참고.

83) Curtis A. Bradley, "Customary International Law Adjudication as Common Law Adjudication", in *Custom's Future: International Law in a Changing World*, Cambridge University Press, 2016.

84) 김상걸, "입법적 국제관습법과 법적확신 개념의 재구성", 『국제법학회논총』, 2020, 25면.

85) Peter E. Benson, "Francois G y's Doctrine of Customary Law", *The Canadian Yearbook of International Law*, 1982, pp. 267-268. (김상걸, "입법적 국제관습법과 법적확신 개념의 재구성", 25면에서 재인용)

무엇인가?

제3장을 시작하면서 필자가 던진 물음은 “무엇이 관습법을 ‘문제적’으로 만드는가?”였다. 이 질문에 대한 일차적 답은, 분석적인 관점에서 보면 우선 논리적인 오류를 범한다는 점에서 문제적일 수 있다. 또한 실천적인 관점에서 보면, 관습법이라는 특별한 법원(法源)의 고유한 가치와 존재 의의를 훼손시키고 부정적 인식을 확산하는 데 적잖은 기여를 하기에 유해할 수 있다. 그런데, 결국 이 문제를 실천적으로 가능하게 하고 이론적으로 정당화하는 유력한 창구는 관습법의 성립 및 효력요건의 이원적 구성이라고 볼 수 있다.⁸⁶⁾

19세기 역사학파의 영향 이래, 전통적 견해들은 관습법의 이원적 성립요건을 도그마적으로 받아들여 왔고, 이는 이론과 실무를 통해 상호지지와 상보적 관계를 형성하고 유지해왔다. 실천적인 면에서 보면 각 요건의 존재와 내용에 대한 입증방식의 자의성이, 이론적 관점에서 보면 ‘선결문제의 오류’나 ‘연대기적 역설’과 같은 난점이 상존한다. 그로인해 한편으로는 관습법의 불안정한 법적 지위에 원인을 제공하고, 다른 한편으로는 그 문제성을 강화하고 정당화하는 유력한 창구가 되기도 한다. 만약 필자의 이런 분석이 타당하다면, 앞서 검토한 두 가지 문제적 현상을 해결하고 극복하기 위한 출발점은 관습법 성립요건의 이원적 구성의 해체와 재구성에서부터 시작되어야 할 것 같다.⁸⁷⁾

86) 국제관습법에도 이원적 성립요건의 문제는 동일하게 존재하는데, ‘두 요소 접근(two-element approach)’으로 불리기도 한다. 보댕은 두 요소 접근법이 갖는 불명확성은 국제공동체의 분권적 성격의 산물이라고 지적한다. Fernando Lusa Bordin, “A Glass Half Full?: The Character, Function and Value of the Two-Element Approach to Identifying Customary International Law”, *International Community Law Review*, 2019, p. 288. 그런데 이런 설명은 국내법 질서를 전제로 한 관습법 논의에 그대로 차용하기에는 한계가 있다. 다만, 국가법 하위 수준에서의 규범 다원주의나 다원적 공동체라는 시각에서 접근해보면 시사점을 얻을 수도 있겠다.

87) 관습법 성립요건의 이원적 구성이 갖는 문제점에 대해 유사한 문제 의식을 보이는 국내 연구로는, 오세혁, “관습법의 현대적 의미”, 『법철학연구』, 2006; 오세혁, “관습법의 본질과 성립요건에 관한 고찰-관련 판례에 나타난 논증에 대한 분석 및 비판”, 『홍익법학』, 2007; 박준석, “신행정수도법 위헌 결정의 논증 분석적 이해”, 『세계헌법연구』, 2013 등 참고.

다른 한편, 객관적-주관적 성립요건의 결합이라는 이원적 구조를 전제로 한 전통적 설명이 갖는 또 다른 문제점은 그것이 관습법을 둘러싼 현실을 제대로 설명하지 못한다는 것이다. 이는 두 가지 점에서 논할 수 있다. 첫째, 기존의 이원적 성립요건의 틀 안에서라면, 관습법이 갖는 규범적 요소는 오롯이 ‘법적 확신’ 개념이 전담하고 사실적 요소는 모두 ‘관행 또는 관습의 존재’라는 객관적 요건에 전가되는데, 이는 현실에 비춰볼 때 부정확한 설명이다. 즉 일부 규범적 관행이나 관습은 성문법규 못지 않게 강한 규범력을 갖는데,⁸⁸⁾ 이러한 현실을 이론적으로 담아내지 못한다. 둘째, 객관적인 성립요건인 관행 또는 관습의 존재 요건은 ‘장기간 지속성’과 ‘반복누적성’이라는 요건을 필수적으로 수반하는데, 이는 국제법영역에서 논의되는 ‘속성 관습법(instant customary law)’⁸⁹⁾과 같은 반례에 무력하다. 즉 중요한 것은 습관화된 반복누적성이 아니라⁹⁰⁾ 조정 문제를 해결하기 위한 해법으로 형성된 관습 규범의 문제해결력과 기능일 수 있다.⁹¹⁾ 이 점은, 주관적 성립요건인 ‘법적 확신’ 개념에 대한 기능주의적 이

88) 관행의 규범성에 대한 연구로는, 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰”, 『법학논총』, 2017; 이현경, “법학적 관행 이론 소묘: 관행의 규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로”, 『법철학연구』, 2017 등 참고.

89) 이와 유사하게 국제사회의 필요에 따라 신속히 형성된 국제관습법의 예로는, 뉴렌베르그 재판, 우주법 형성, 대륙붕에 관한 트루먼 선언, 나토의 코소보 공습 등이 있다. 이러한 사례들을 ‘그로티우스의 순간(Grotian Moment)’이란 표제어로 총칭한 연구는, Michael P. Scharf, “Seizing the ‘Grotian Moment’: Accelerated Formation of Customary International Law in Times of Fundamental Change”, *Cornell International Law Journal*, 2010, pp. 439-469. (김상걸, “입법적 국제관습법과 법적확신 개념의 재구성”, p. 38, 각주 135.에서 재인용)

90) 이와 관련해서는 머피의 통찰을 참고할 수 있다. 머피는 흄의 노젓기 사례를 예로 들면서, 습관적 요소가 부재하지만 조정문제 해결을 위한 규범으로 기능할 수 있는 규범의 가능성을 시사한다. “노젓기를 조정하는 두 사공들은 그 어떤 습관의 요소 없이 단일한 혹은 의도적인 모방에 의해 그렇게 한지도 모른다.” James Bernard Murphy, “Habit and Convention at the Foundation of Custom”, in *The Philosophy of Customary Law*, Oxford University Press, 2014, p. 54.

91) 피니스도 국제관습법을 배경으로 ‘관습법의 권위’의 근거를 공동선의 증진과 조정 문제의 해결에 기반한 기능주의적 설명을 한다고 볼 수 있다. 피니스는 집단의 공동선을 목적으로 한 방법은 만장일치와 권위 둘 중 하나를 반드시 택해야 한다고 하면서, 관습법의 권위를 ‘메타-관습(meta-custom)’ 개념을 통해 정당화한다. 그리고 메타-관습을 통한 설명은 전통적 견해들이 해결하지 못한 선결문제 오류라는 역설 문

해로도 연결될 수 있다. 즉 장구함(長久)에 의존하여 법적 확신을 확인 보증하는 것이 아니라, 조정 문제의 해결에의 필요성(*necessitatis*)에 방점을 두고 법적 확신 개념을 이해할 수도 있다. 이러한 기능주의적 접근에 의하면, ‘법적 확신’은 과거에 이미 존재해왔던 법규범에 대한 믿음이나 사후적 인증이라기보다는, 현재 혹은 미래의 조정 문제 해결에 대한 공동 승인이나 집단 지향성 혹은 의지(*collective intentionality*)의 문제로 풀여갈 수도 있다. 이렇게 되면, 앞서 제기한 ‘연대기적 역설’⁹²⁾과 순환논법의 오류도 해소할 수 있게 된다.⁹³⁾ 그리고 관습법은 본질적으로 ‘과거지향적’이거나 ‘회고적’이라는 선입견을 불식시키고, 오히려 미래지향적인 법원으로 재조명할 수도 있다. 요컨대, 기존의 전통적 견해들의 이분법적 틀을 통해 이해되는 관습법은 결국 그러한 인식 틀 안에 갇혀서 그 본질에 대한 제한적이고 왜곡된 이해로 이어지고, 관습법이 내포하는 특별한 잠재적 역량과 활용 가능한 가능성 자체를 차단하는 효과를 낳는다.⁹⁴⁾ 그렇다면 이 문제를 해결하기 위한 근본적이고 최우선적인 방법은 기존의 이론 틀을 벗어나 완전히 새로운 관점에서 관습(법)의 본질을 해명해보려는 시도일 것이다.

지금까지의 논의를 정리해보자. 이 글의 제2장과 제3장을 통해 필자는 관습

제도 해소한다고 주장한다. John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed, Oxford University Press, 2011, pp. 231-245.

92) 국제법에서 ‘연대기적 역설’의 해소 문제를 직접적으로 다루고 있는 글로, Lefkowitz, “(Dis)solving the Chronological Paradox in Customary International Law: A Hartian Approach” 참고.

93) 국제법이론에서는, 국제관습법의 주관적 요건이 야기하는 ‘연대기적 역설’을 해결하기 위한 시도로 ‘실수이론’이 있다. ‘실수이론’은 국가들이 실제로는 법적 구속력이 없는 법규범을 법적 구속력이 있다고 믿는 실수로 ‘연대기적 역설’을 설명한다. 김상걸, “입법적 국제관습법과 법적확신 개념의 재구성”, 26면. ‘실수이론’에 대한 추가 설명은, Josef L. Kunz, “The Nature of Customary International Law”, *American Journal of International Law*, 1953, p. 130.

94) 이러한 이론 틀은 19세기 역사학과와 근대민법이론의 성과에 상당히 의존하는데, 학자에 따라서는 ‘성숙되지 못한 요건’이라는 현대적 평가를 하기도 한다. “관습국제법은 성숙되지 못한 요건을 통해 법으로서의 지위를 인정받기 때문에 많은 국제법 규범의 관습국제법으로서의 지위나 내용은 불안정성과 불확실성을 동반한다.” 김화진, 『국제법이론』, 26-27면.

의 법적 지위를 둘러싼 법철학 논쟁과 관습법을 둘러싼 문제적 현상들을 검토하였다. 이제는 앞선 논의와 접맥하면서 두 줄기를 하나로 아울러, 공통 원인을 진단하고 해결책을 모색할 때이다. 결론적으로, 관습의 규범력이나 법규성의 근거를 논하기 위해서는 일차적으로는 두 가지 틀을 극복해야 할 것이다. 첫째는, (제2장에서 검토했던) 명령주의적 법실증주의자들이 주장한 처벌이나 제재의 위협과 같은 환원주의이고, 둘째는, (필자의 분석에 따르면 명령주의적 실증주의 역시 전제하고 있는 틀인) 관습법 성립요건의 이원적 구성이다. 이러한 이분법⁹⁵⁾은 모든 종류의 관습법 —국내·국제관습법, 개별법영역별—에 공통적이기에,⁹⁶⁾ 일반 이론의 차원에서부터 이 문제를 다룰 수 있다.

IV. 관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해

필자는 앞서 관습법 성립요건의 이원적 구조와 기존의 법이론적 틀이 여러 차원에서 문제를 야기하는 기초를 제공한다고 지적했다. 따라서 관습의 본질과 법규성을 제대로 규명하기 위해서는 새로운 관점의 도입과 방법론적 혁신이 요청된다. 제3장까지는 법기관의 제도적 개입과 사법 활동이 전제된, 즉 법체계라는 울타리를 배경으로 논하였다면 본 장에서는 가장 근본적인 철학적 분석⁹⁷⁾작업에서부터 시작한다. 첫째, 관습 개념을 구성하는 더욱 기초적인 두

95) (이론가마다 표현법은 다르지만) 관습을 사실적/객관적/외적 측면과 규범적/주관적/내적 측면 등으로 구분하는 이분법이다. 가령, 포스테마는 관습이 외적 요소 —행위의 정규성(usus)—와 내적 요소-관습을 따르는 사람들이 그 정규성(regularity)에 따르는 행위가 법적으로 요청된다는 확신(opinio juris)으로 분해한다. Gereald J. Postema, "Custom, Normative Practice, and the Law", *Duke Law Journal*, 2012, p. 708.

96) 베더만은 '범원으로서 관습'에 대한 광범위한 법철학적 설명을 제공한다. 특히 관습법의 문제를 ① 특정 관점에서의 관습법: 인류학, 문화, 역사, 경제학, 사회학, 심리학, ② 국내법체계에서의 관습: 가족법, 재산법, 계약법, 불법행위법, 헌법, ③ 국제법에서의 관습: 사적 국제법, 공적 국제법의 세 파트로 나누어서 풍부하고 상세히 고찰한다. David J. Bederman, *Custom as a Source of Law*, Cambridge University Press, 2010 참고.

97) 법에 대한 '철학적 분석(philosophical analysis)'은 법의 본성에 대한 개념분석적

개의 기초 개념으로 분해하여 분석한 후, 이를 기초로 관습 개념에 관한 두 개의 구성적 관계식(① 관습 $\rightleftharpoons$ 관행*습관(화), ② 관행 $\rightleftharpoons$ 규범적 규칙*사회적 실천 $\rightleftharpoons$ 규범적 실천)을 제안한다. 둘째, 도그마적으로 받아들여져온 관습법 성립요건의 이원적 구성에 대한 해체와 재구성을 시도한다. 이 두 가지 시도는 관행을 분석을 중심에 놓는 ‘관행주의적 분석’⁹⁸⁾과 ‘실천-중심적 접근’이라는 점에서 공통점이 있다.⁹⁹⁾ 그리고 이를 기초로, 셋째, 관습법의 권위와 법규성에 대한 새로운 시각과 정당화 이론을 제시한다. 본 장에서의 이러한 작업은 제3장에서 논한 ‘관습 없는 관습법’과 ‘관습법의 역설’이라는 문제적 현상들의 철학적 토대를 점검하고 이론적인 해결을 모색하려는 근본적 시도로도 볼 수 있다.

1. 관습 개념의 철학적 기초 분석

(1) 관습 $\rightleftharpoons$ 관행 * 습관(화)

앞서 제기한 문제들을 해결하기 위해서는 가장 근본적이고 토대적인 차원에서 ‘관습 그 자체’에 대한 철학적 분석 작업에서부터 시작하는 것이 올바른 출발점이 될 수 있겠다. 그런 차원에서 필자는 관습을 구성하는 두 개의 더욱 기초적인 개념 단위로 ‘관행’과 ‘습관(화)’를 구분하고, 각 요소의 특징과 그 결

탐구와 가치론적 평가를 시도한다는 점에서 특히 역사적 분석, 경제학적 분석이나 사회학적 분석과는 차별화된다. 참고로, 비용-편익의 관점에서 “가격 이론(price theory)”에 기하여 관습법에 대한 경제학적 분석을 시도하는 간략한 글로는, Francesco Parisi, “Customary Law”, in *The Encyclopedia of Public Choice*, Edited by Rowley & Schneider, 2003, pp. 136-138을 참고할 것.

98) ‘관행주의(conventionalism)’란 어떤 현상이 관행으로부터 발생하고 관행에 의해 결정된다는 교의를 의미한다. Michael Rescorla, “Convention”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2019, p. 4. 따라서 이 글에서 관습의 본질을 탐구함에 있어 방법론상 ‘관행주의적 분석’을 취한다는 것은, 그 개념소인 관행에 대한 분석을 중심에 놓고 접근한다는 것이다.

99) 필자는 궁극적으로 ‘실천 중심적 접근’, 그리고 필자가 규범적 실천으로 재구성한 ‘관행주의적 분석’을 중요한 방법론으로 채택한다. 이러한 접근은, 본고 제2장에서 관습의 법적 지위를 둘러싼 법철학 논쟁사를 검토하는 과정에서도 일관되게 강조하였다. 일례로, 하트의 ‘궁극적 승인율’에 대해서도 규칙 그 자체의 존재론 편향적인 이해를 넘어 ‘승인적 실천’이라는 점에서 바라볼 필요가 있다고 주장했다.

합 효과를 규명함으로써 관습의 본질에 대한 새로운 이해를 구하고자 한다. 이는 기존 이론에 대한 수정주의적 접근이 아닌, 새로운 출발(fresh start)로 볼 수 있다.

우리의 사회적·정치적 삶 속에서 관습이 갖는 심대한 중요성에도 불구하고 관습과 관습법은 엄밀한 철학적 검토에서 비껴있었다. 최근에는 습관이나 관행에 대한 철학적 분석은 있지만, 정작 관습에 대한 철학적 분석서는 찾아보기 어렵다.¹⁰⁰⁾ 머피(James Bernard Murphy)도 주장하듯이,¹⁰¹⁾ 관습의 본질에 대한 철학적 탐구는 그 개념을 구성하는 두 개의 기초 개념인 관행과 습관으로 분해하여 접근할 때 가능하며, 따라서 관습에 대한 건설한 이론은 각 요소에 대한 철학적 설명을 토대로 재정립될 필요가 있다. 두 단계로 정식화하면 다음과 같다.

[T1] 관습(custom) ≍ 관행(convention) * 습관(화)(habit(uation))

[T2] 관행 ≍ 규범적 규칙 * 사회적 실천 ≍ 규범적 실천

(2) 관행주의적 분석

위의 두 관계식에 따르면 우선 관행과 관습을 개념적으로 구별할 수 있다.¹⁰²⁾ 이를 토대로 관습의 본질 규명에 있어, 그것을 구성하는 필수요소인 관

100) 철학자들에게도 그간 관습은 특별한 철학적 이해 관심을 끌지 못했다. 예컨대 철학의 여러 분과에서 “관행 이론은 있지만 관습 이론은 없다.”는 지적도 귀 기울여들을 만하다. James Bernard Murphy, *The Philosophy of Customary Law*, Oxford University Press, 2014, p. ix.

101) 머피도 ‘관습’은 ‘습관’과 ‘관행’이라는 더 기초적인 두 관념으로 분석되어야 한다고 주장하면서 각 요소의 고유한 특징에 주목한다. “습관과 관행은 논리적으로 독립적이다. 모든 습관이 관습적 습관인 것은 아니며, 많은 습관들은 완전히 특이하며 관행들을 조정하는 데 기여하지 않는다. 유사하게, 많은 관행들은 습관이 아니다. 실제로, 무엇이 패셔너블한지를 정하거나 암호를 정하는 관행과 같이 어떤 관습들은 결코 습관이 되지 않도록 설계된다. 수학자들과 다른 전문가 집단들은 적어도 최초에는 습관적이지 않았던 표기법, 절차, 프로토콜에 관한 명시적인 관행들을 종종 채택한다.” Murphy, “Habit and Convention at the Foundation of Custom”, p. 54.

102) 참고로, 박준석 교수는 “관습법의 개념이 ‘관행의 반복 ⇒ (사실인) 관습의 정립 ⇒

행을 중심으로 이해하는 관행주의적 분석을 시도해 보자.

선행연구에 따르면, 관행의 본질은 조정 문제를 해결하기 위해 등장한 해법으로 이해할 수 있다. 즉 관행이란 “합리적 주체가 공동의 조정 혹은 협력 문제에 직면하여 실천적 추론 과정을 통해 수립된 균형점으로, 명시적인 합의나 약속이 없이도 행위자들 간의 사회적인 상호작용을 통해 형성되고 자율적으로 존속하는 묵시적인 규범적 질서”¹⁰³⁾이다. 위 정식 [T1]에 의하면 관행에는 습관성의 요소가 필수적이지 않다. 즉 전통적 견해들에서 공통되게 발견되는 관습에 대한 이해방식 안에서 요청되는 시간 지속성(장구성(長久))과 반복·누적성은 관습 개념을 구성하는 또 다른 기초 개념인 ‘습관(화)’ 요소를 통해 구현되기에, 관행 개념 안에는 그러한 요건들이 반드시 요구되지는 않는다.¹⁰⁴⁾

또한 관행주의적 분석에 의하면, 관습 정식의 두 번째 명제 [T2], 즉 “관행 ≡ 규범적 규칙 * 사회적 실천 ≡ 규범적 실천”을 중심으로 관습의 동적 측면과 규범성을 더 잘 해명할 수 있다. 명제 [T2]에 따르면, 관행의 개념 정식을 통과한 진성 관행¹⁰⁵⁾은 규범적 규칙으로 이해될 수 있기에 그 자체에 지시 내용과 규범성을 내포한다.¹⁰⁶⁾ 그런데 도덕 규범과 대비해보면, 관행은 규칙으로서의 지시 내용이 전부를 이루지 않는다. 더욱 중요하게 강조되는 것은 관행은 ‘실

법적 확신의 부여라는 (단선적인) 발생단계 모델을 통해 해명될 수 있다고 보는 통속적인 견해”로 정리하면서 비판적인 입장을 보인다. 박준석, 『법사상, 생각할 의무에 대하여』, 238면. 하지만 필자가 이 글에서 제안한 관습 정식[T1]이 반드시 박준석 교수가 묘사한 ‘단선적인 발생단계 모델’을 함의하지는 않으며, 관행에 근거하지 않은 관습의 성립 가능성에 대해서도 언급한 바 있다. 이현경, “법학적 관행이론 소묘” 참고.

103) 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소-관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초”, 『법철학연구』, 2017, pp. 168-169.

104) 양선숙 교수도 이와 유사한 생각을 말한다. “노 젓기 모델은 흠이 사용하는 ‘일치’로서의 관행의 의미를 잘 드러내지만 이 일치는 일회성이라는 점에서 시간적 지속을 두고 기존의 것이 된다고 하는 관행 일반의 반복성 요소가 없다.” 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해”, 『법철학연구』, 2012, 49면.

105) ‘진성 관행’과 ‘법적 관행’의 개념과 요건에 관해서는, 이현경, “법적 관행의 개념과 그 요건”, 『법학논총』, 2017 참고.

106) 규범성에는 두 차원 -행위 향도적 속성과 의무 창출적 속성- 이 존재하며, 요건을 충족한 진성 관행에는 규범적 위계가 있다. 관행의 규범성에 대한 추가 설명은, 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰” 참고.

천됨(being practiced)'을 존재론적 기반으로¹⁰⁷⁾ 하는 규범적 질서라는 점이다. 즉 규칙 그 자체의 측면보다는 사회적 실천으로서의 관행의 특질이 여타의 규범 유형과 관행을 차별화시켜주는 특징이 된다. 또한, '규범적 실천'으로서 관행은 실천적 추론의 과정에서 일종의 안정된 매듭(node)으로 기능한다. 여기서의 핵심은 '현저성(salience)'에 있는데,¹⁰⁸⁾ 이를 통해 조정 문제를 해결할 수 있다.¹⁰⁹⁾ 즉 조정 문제 해결을 위한 관행의 핵심 역량은 행위 정규성(regularity)이 아닌 현저성에 있다. 요컨대, 조정 규범이나 규범적 실천으로서 관행에 '습관성'의 요소가 더해지면 사실적으로나 규범적으로 더욱 견고한 규범적 질서로서 관습이 되는 것이다. 이런 설명은, 기존의 전통적 견해를 통해서서는 포착되기 어려운 관습의 중요한 다른 측면들을 제대로 이해할 수 있도록 한다. 결론적으로, 관습의 개념을 이루는 필수 개념소인 '관행'을 중심으로 관습 개념을 재구성하고, 관행을 조정 문제 해결을 위한 해법으로 이해하는 관행주의적 분석은 궁극적으로 관습법의 정당화 문제에 있어서도 기능주의적 접근을 가능하게 한다. 이 점은 본고 제4장 제3절에서 논해지는 피니스의 '메타-관습'을 통한 관습법의 권위 이론과도 연결될 수 있다. 그리고 미래지향적 법원으로서 관습법을 재조명하기 위한 철학적 기초를 제공할 수 있다.

(3) 관습 정식에서 '습관(화)'의 의미와 역할

그렇다면 위의 관습 정식[TI], “관습 ≡ 관행 * 습관(화)”에서 습관화란 무엇일

107) 콜먼의 글에서도 유사한 생각을 발견할 수 있다. “규칙과 실천 간의 관계에 관한 가장 중요한 점은, 승인율은 그것이 *실행되는(is practiced)* 오직 그 경우에만 행위를 규율하는 규칙으로 존재하게 된다는 점이다.” Coleman, *The Practice of Principle*, p. 78.

108) 이러한 통찰은 포스테마로부터 빌려왔다. 포스테마는 관행이 법적 추론 과정에서 수행하는 역할을 중심으로 관행의 본질을 이해하는데, 이를 기초로 '현저성 추론(salience reasoning)'이라는 추론 기법과 모델도 제안한다. 자세한 사항은, Gerald J. Postema, “Salience Reasoning”, *Topoi*, 2008. 여기서 '매듭'이란 용어는 조홍식 교수의 표현을 참고했다. 조홍식, 『사법통치의 정당성과 한계』, 박영사, 2009.

109) 포스테마도 관행을 통계적 루틴이 아닌 실천적 숙고의 역동적 네트워크 안에서 상대적으로 안정된 매듭으로 간주해야 한다고 주장한다. Gerald J. Postema, *Legal Philosophy in the Twentieth Century; The Common Law World*, (editor Enrico Pattaro), Springer, 2011, p. 192.

까? 앞선 관행주의적 분석에 의하면, 관습은 관행이 ‘습관화’의 과정을 거치면서 사실성과 규범성이 강화되고,¹¹⁰⁾ 그로 인해 더욱 공식적이고 견고화된 질서인 관습으로 변모한 것이다. 여기서 ‘습관 또는 습관화¹¹¹⁾’는 기본적으로 장기간의 ‘시간 지속성’[장구성(長久)]과 양적 차원에서의 ‘반복 · 누적성’을 의미한다. 특히나 관습을 구성하는 기초 개념의 한 축인 관행을 조정 규범으로 이해한다면, 관행에 이런 습관성이 부착된 관습 규범의 조정력은 더욱 증대될 것이다.¹¹²⁾

여기서 한 걸음 더 나아가 철학자 라베송(Felix Ravaisson)의 설명에 주목해보자. 라베송은 “습관이란 일단 형성되면 일반적이고 영속적으로 존재하는 방식”이며, “습관은 그것의 원인인 변화를 넘어 존속한다.”고 주장하였다.¹¹³⁾ 만약 이 설명을 받아들인다면, 우리는 ‘습관’의 개념 안에도 역동성과 가변성을 담을 수 있게 된다. 그리고 ‘습관화’도 모종의 고체화 과정이라기보다는, 환경에 기민하게 반응하면서 적응하는 역동적 과정으로 재규정할 수 있게 된다. 이런 점은 필자가 극복하고자 하는 관습에 대한 선입견들, 예컨대 ‘과거지향적’ ‘회고성’, ‘경직성’, ‘고정성’ ‘시대착오적’이거나 ‘구태의연함’¹¹⁴⁾ 등과 같은 부당

110) 필자는 선행 연구를 통해, 관행의 ‘성립 · 존재 조건’과 ‘강화 조건’을 구분했다. 사실적으로나 규범적으로 강력한 관행을 만드는 ‘강화 조건’으로 ① 공통지식과 공식적 표명, ② 시간적 지속과 반복, ③ 제도적 지지, ④ 도덕적 이유들을 제시했다. 이현경, “법학적 관행 이론 소묘”, 34-35면 참고.

111) 사우스우드도 ‘습관화’라는 표현을 사용하면서 습관이 갖는 힘을 설명한다. 그는 연관된 실천(relevant practice)에 일치되게 행동하는 것은 습관화와 문화적응(acculturation)으로 이어지고, 이를 통해 특별한 종류의 규범성을 획득하게 된다고 한다. Nicholas Southwood, “The Moral/Conventional Distinction”, *Mind*, 2011, p. 780.

112) “관행이 습관적이게 되면 우리의 활동들을 더욱 효과적으로 조정한다.” Murphy, “Habit and Convention at the Foundation of Custom”, p. 13.

113) 라베송은 “최광의로서 습관이란 일반적이고 영속적인 존재(etre) 방식”이라고 정의한다. 그리고 “습관은 단지 어떤 상태인 것만이 아니라 어떤 기질(disposition)이자 덕성(vertu)이다.” Felix Ravaisson (최화 옮김), 『습관에 대하여』, 자유문고, 2016, 69-71면.

114) 법철학에서 이런 비판적 입장의 일례로, 임미원, “대법원의 유체인도 판결의 법철학적 고찰”, 『법조』, 2013; 공법이나 행정법 영역에서의 비판으로는, “박정훈, 『행정법의 체계와 방법론』, 박영사, 2005, 126면.

한 인상¹¹⁵⁾을 제거하고 관습을 미래지향적 법원으로, 관습법의 현대적 변환을 꾀할 수 있는 이론적 자원을 제공할 수 있을 것이다. 이와 관련하여 아래의 인용문은 많은 시사점을 제공하며, 관습법의 본질에 대한 새로운 이해 가능성의 창을 열어준다.

관습법은 성문법의 반대 개념일 뿐, 새로운 법의 반대 개념이 아니다. 관습법은 불문법일 뿐이지 낡아빠진 법이 아니다. ...관습이 전통의 의미를 담고 있지 않다는 점, 그리고 오로지 성문법에 반대되는 개념일 뿐이라는 점을 가장 잘 보여주는 것은 사람들이 일반적으로 관습이 변화한다는 점을 인정하고 있을 뿐 아니라 성문법의 경직성에 대비하여 관습의 유연성을 전면에 내세우고 있다는 사실이다. 관습은 행해져 온 관행을 담고 있을 뿐만 아니라, 그를 변경할 수도 있지 않은가? 관습은 전통적인 것은 물론이고 혁신적인 것까지도 포함한 일체의 불문 규범을 포섭하는 것이 아니던가?¹¹⁶⁾

2. 관습의 권위

(1) 법체계의 권위에 의탁하지 않은 법규성 해명

본고 제2장과 제3장에서는 기존에 법실증주의 진영을 중심으로 이해되어온 관습법에 대한 이해방식을 기초로, 관습의 법규성의 근거 역시도 공적인 국가기관의 제도적 권위에 의거하여 논하였다. 가령 ‘관습법은 법관법이다’라고 주장하는 회의론적 전통에서는 결국 사법부의 권위에 의존하여 문제를 풀어갔다. 반면 입법에 의한 관습법의 보충이나 성문화를 주장하는 입법론적 환원주의자들은 제정법 중심주의, 우위 원칙에 기대어 관습법의 불완전성을 민주

115) 반대로, 관습법이 사회에서 긍정적 기능을 수행한다는 평가도 있다. ① 고정된 성문법과 변화하는 사회 사이의 간극을 메우는 기능, ② 공익적 기능을 수행한다고 한다. “관습법상 법정지상권은 건물 존속 보장이라는 공익적 기능을 수행한다고 평가되어 왔다.” 권영준, “법률행위로 인한 관습법상 법정지상권 폐지와 법정임대차 도입”, 『민사법학』, 2014, 4면.

116) R Capitnat, “La costume constitutionnell”, *Gazette du Palais*, 1929, reprinted in *Revue du droit public*, 1979, pp. 959-960. (김기창, “성문헌법과 ‘관습헌법’”, 『공법연구』, 2005, 96면에서 재인용. 강조는 필자)

적 정당성을 가진 입법부의 제도적 권위를 통해 보충하려고 하였다. 하지만 필자가 지적하였듯이, 이러한 두 가지 방식의 환원주의적 접근은 관습의 본질과 그 특유성을 몰각시키는 우를 범할 가능성이 있다. 다음의 인용문과 같은 카우프만의 주장도 일리 있다. 하지만 이런 설명은 추상적이고 두루뭇술하여서 좀 더 체계적인 이론과 초점화된 논변의 형태로 재구성될 필요가 있다.

관습법도 실정법이다. 그러나 그 실정성은 국가의 입법행위에 근거하는 것이 아니라, 공동사회의 법효력을 요청하는 의지와 연결되어 오랜 기간 지속된 규칙의 동일한 시행에 근거한다.¹¹⁷⁾

국가기관의 제도적 권위에 기생하지 않는 방식으로, 즉 ‘입법’이나 ‘사법’을 통하지 않고(제도적, 공식적인 국가기관의 유권적/제도적 실천을 원조받지 않으면서도)¹¹⁸⁾ 관습의 범규성과 법적 지위의 근거를 구할 대안 이론이 요청된다. 이런 문제의식 하에, 이하에서는 앞선 관행주의적 분석을 기초로 한 관습의 본질에 대한 새로운 이해를 기초로 관습의 권위와 정당화 문제를 다룬다. 가령 범명령설의 경우에는 ‘say-so legislative authority’(이하, SSLA 모델)에 근거하고 있는데, 관습법의 경우 그 권위의 원천과 형태는 어떻게 되는가?¹¹⁹⁾ 이 질문에 답하기 위해서는 두 단계에 걸쳐 체계적으로 사유를 확장해볼 수 있다. 우선 첫 번째 단계로는, 기존의 지배적인 견해인 ‘SSLA’ 모델 안에서 일정한 수정을 가한다면 관습법의 경우에도 설명 가능한가? 만약 그것이 어렵다면, 두 번째 단계로, 새로운 독자적 논거를 제시할 수 있는가?

117) Arthur Kaufmann (김영환 옮김), 『법철학』, 나남, 2007, 236면.

118) Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 412.

119) 참고로, “the crucial question is whether an authorless customary norm could ever enjoy legitimate authority. That is, could the customary norm’s “claim” to direct the behavior of those it addresses ever be justified?” Lefkowitz, “Customary Law and the Case for Incorporationism”, p. 411. 하지만 여기서 ‘authorless customary norm’ 중 ‘authorless’란 수식은 재고해 볼 필요가 있다. 왜냐하면, ‘author’ 개념을 어떻게 이해하는지에 따라 관습규범의 경우 ‘author’가 부재하는 것이 아니라 다른 형태로 존재한다는 주장도 가능하기 때문이다. 이를 정치철학과 연계시켜 보면 ‘주권(sovereignty)’ 이론과도 상통할 수 있다.

(2) 권위의 중심의미

라즈(Joseph Raz)의 탁월한 권위론¹²⁰⁾이 소개된 이후, 법의 규범성 담론에서는 법실증주의와 비실증주의를 막론하고 ‘권위(authority)’ 개념을 중심으로 한 논의가 증가했다. 이런 경향은 자연법론 혹은 비실증주의 진영에서도 예외는 아니었는데, 대표적인 현대 분석적 자연법론자로 평가되는 피니스(John Finnis) 역시 자신의 대표 저서인 *Natural Law and Natural Rights* 제9장 “권위” 챕터에서 관습법의 문제를 다루고 있다.¹²¹⁾

피니스는 권위가 왜 필요한지, 그리고 권위를 어떻게 정당화할 것인지에 대한 질문들은 다양한 방식으로 제기될 수 있다고 지적하면서, ‘실천적 합당성(practical reasonableness)’과 ‘공동선(common good)’ 개념을 중심으로 한 이론 체계를 구축한다. 피니스는 기본적으로 ‘행위 조정 문제(coordination problem)’¹²²⁾

120) Joseph Raz, *The Authority of Law : Essays on Law and Morality*, 2nd, Oxford University Press, 2009; Raz, “권위, 법 그리고 도덕”; 박준석, “조셉 라즈의 권위론에 대한 비판적 고찰”, 『법철학연구』, 2007 참고.

121) 피니스는 이 책에서 다음과 같은 ‘경험칙’을 제시한다. “어떤 개인이 발한 명문 규정들(stipulations)이 권위를 갖는 것은, 실천적으로 합당한 관점을 취하는 주체가 공동선을 염두에 두고 볼 때 그 명문 규정들에 대해 마땅히 동의해야한다고 판단할 경우이다.”

122) ‘행위 조정 문제’ 개념은 울만-마가릿의 중요한 저서를 통해 체계적으로 제시되었고, 현재까지도 경제학, 심리학, 법학 등 여러 분야에서 수용되어 발전적으로 계승되고 있다. 울만-마가릿은 행위 조정 문제를 다음과 같이 정의한다. “행위조정 문제는 상호의존적 결정에 의해 특징지워지는 상호작용 상황을 말한다. 즉, 행위조정 문제는 두 명 혹은 그 이상의 사람들이 관련된 상황으로, 각자가 여러 가지의 행위 선택지들로부터 하나를 선택해야만 하며, 또한 어느 한 사람의 행위 결과는 다른 사람들 각자가 선택한 행위에 따라 좌우되는 상황을 일컫는다. 이와 같은 상황집합 내에서 행위조정 문제의 특별한 차별성은 당사자들의 이해관계가 일치하는 상황이라는 점이다.” Edna Ulmann-Margalit, *Emergence of Norms*, Oxford University Press, 1977, p. 78. 피니스는 그의 저서에 주석에서 울만-마가릿의 이 설명을 그대로 인용하고 있다. (John Finnis, “Authority”, in *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed, Oxford University Press, 2011, 주석 IX.1.-2.) 포스테마 역시 울만-마가릿의 설명을 적극적으로 받아들이고 법적 차원으로 적용하여 조정 문제 개념을 더욱 체계화하고 확장하였다. 자세한 사항은, Gerald J. Postema, “Coordination and Convention at the Foundations of Law”, *The Journal of Legal Studies*, Vol. XI, 1982. 참고. 또한 게임이론적 행위조정 문제를 ‘협력적 상호작용 문제’로 확장하여 대안적 개념관을 제시하는 국내 연구로는, 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요

를 광의로 이해하면서, 법의 주요한 기능을 공동 목표나 공동선의 달성을 위한 조정이라고 한다.¹²³⁾ 이러한 조정적 법관념을 갖고 있는 피니스는 “공동의 목표나 공동선을 달성하도록 조정하는 행위 선택지들 중에서 하나를 선택하는 것으로는 결국 두 가지 방식, 즉 만장일치나 권위에 의한 결정이 그것이며 이외에 제3의 방식은 없다.”고 말하면서, 만장일치가 실제로 실현될 가능성이 없는 공동체에서는 “권위가 만장일치제의 대체물로 필요하다는 것이 공리(axiom)”라고 명시적으로 밝힌다.¹²⁴⁾ 피니스의 설명에 따르면, 어떤 것(가령 어떤 견해, 발언, 지도, 지령, 규칙 등)을 권위 있다고 하려면, 우리가 그것이 주장하는대로 믿거나 그것이 요구하는 대로 행동할 충분한 이유를 그것이 우리에게 제공할 경우에만 오직 그러하다고 한다.¹²⁵⁾ 피니스는 라즈의 배제적 이유(exclusive reason)에 기한 권위 설명도 수용하면서, “어떤 것을 권위로 여긴다는 것은, 조셉 라즈의 유용한 용어법에 따르면 배제적 이유로 여긴다는 의미”라고 설명하면서, 그것을 ‘권위의 중심의미’라고 한다.¹²⁶⁾ 그리고 이러한 중심의미는, 그것이 이론적 권위든 실천적 권위든, 권위가 한 개인에게 귀속되는지 혹은 그의 특성에 귀속되는지, 아니면 누군가의 견해나 발언에 귀속되는지 아니면 그 지시자에게 권위가 있었다는 이외의 이유로 인해 권위 있는 의견이나 지시(예컨대 관습이나 관행)에 귀속되든지와 무관하게 “모든 권위에 타당하다”고 말한다.¹²⁷⁾ 즉 기존에 전통적인 권위론이 보였던 특정한 권위자의 발화에 기한, 말하자면 ‘say-so authority’가 아니라도, 그것이 배제적 이유로 기능할 수 있다면 ‘권위를 갖는다’는 진술이 가능하다는 것이다. ‘권위의 중심의미’를 이렇게 설정함으로써, 피니스는 안전하게 ‘관습의 권위’를 논할 수 있게 된다.

소”, pp. 149-163. 참고.

123) John Finnis, “Law as Coordination”, in *Philosophy of Law*, Oxford University Press, 2013.

124) John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed, Oxford University Press, 2011, pp. 231-233.

125) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 233-237.

126) 피니스는 ‘X가 권위를 갖는다’는 진술의 핵심 의미에 대한 언어상의 혼란으로 인해 법실증주의와 자연법론자들 사이에 심각한 혼동이 생긴다고 지적한다.

127) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 233-237.

(3) 관습법의 권위와 관습법의 역설 해소

피니스는 *Natural Law and Natural Rights*에서 “관행 또는 관습법의 형성과정”을 권위 개념과 연결지어 설명한다. “규칙제정의 권위를 가진 사람이 만들어내지 않았고, 심지어 규칙을 권위적으로 수립하는 방식이 주는 이점도 누리지 못하는데도 권위적 규칙이 어떻게 생겨나게 되는지(즉, 공동체를 규율하기 시작하는지)”¹²⁸⁾를 다루겠다고 한다. 피니스는 관습법의 문제를 논함으로써 ① ‘규칙의 권위를 승인하는 것’과 ‘실천적 합당성의 원리들을 따르는 것’ 사이의 관계에 대한 더욱 깊은 이해를 도모하고, ② 한 공동체에서 만장일치와 권위 사이에는 어떤 차이점과 연관성이 있는지도 해명될 것이라고 기대한다.¹²⁹⁾

피니스는 국제관습법 문제를 중심으로 논의를 펼친다. 그는 ‘법적 확신(*opinio juris*)’이라 불리는 특정한 태도, 믿음, 의도, 성향이 관습법 형성의 해명하기 힘든 난제라고 지적한다. 왜냐하면 고전적인 설명과 견해들은 내려야 할 결론을 미리 전제로 삼은 ‘선결문제의 오류’를 범하거나 역설에 빠져 있기 때문이다. 이는 제3장에서 검토한 ‘관습법의 역설’의 두 번째 차원과도 연결된다. 이 문제를 잠시 다시 짚어보자.

오펜하임(L. F. L. Oppenheim)이 지적하듯이, “누구나 명백히 알 수 있도록 일정 행위들을 반복적으로 하는 습관이 있고, 그 행위들이 의무를 부과하거나 정당하다는 확신에 의해 뒷받침되면서 이 습관이 점차 견고해질 때, 국제법 법률가들은 관습법이 존재한다고 말한다.”¹³⁰⁾ 그런데 관습법의 형성과 존재에 대한 이런 견해는 역설에 빠지게 되는데, 왜냐하면 관습 규범이 이미 (권위를 갖는 규범으로서) 존재하고 있다는 필연적으로 잘못된 믿음에 의거할 때에만 비로소 관습 규범이 존재한다(즉, 권위 있게 된다)는 견해를 제안하기 때문이다.¹³¹⁾

128) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 238-244.

129) 피니스는, 관습이란 ‘권위 있는 관습 규칙’의 준말로, 그리고 여기서 ‘권위 있는’이란 표현은 ‘법적으로 권위 있는’의 준말로 사용하겠다고 밝힌다.

130) Lassa Francis Lawrence Oppenheim, *Oppenheim's International Law*, Vol. I, 8th ed., H. Lauterpacht, Lodon: 1955, sec. 17. 비슷한 취지로 the International Court of Justice in the *North Sea Continental Shelf Cases*, I.C.J. Rep. 1969, p. 44. (Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, chap. 9.에서 재인용)

131) 본고 제3장에서 필자는 ‘관습법의 역설’이라는 표제어 하에, 이러한 역설적인 ‘선결문제의 오류’ 혹은 순환논법 문제를 포함시켜 논하였다.

이러한 문제 상황 속에서, 피니스는 “이 역설로부터 벗어날 수 없었던 입장을 이해하도록 해주는 관습법 형성론”을 제시할 수 있다고 자신한다. 문제 해결을 위한 열쇠는 한편으로는 실천적 판단에, 다른 한편으로는 실천이 존재하는지 여부와 어느 정도로 확고하게 존재하는지에 대한 경험적 판단을 구별하는 것에 있다고 한다.¹³²⁾ 즉, “관습법 형성의 근거에, 특히 통상 법적 확신으로 이름 붙여진 요소의 핵심에는 두 가지의 서로 다르지만 상호 연관된 실천적 판단이 놓여있다.”¹³³⁾ 다만 이 두 가지 판단은 경험적 판단이 아닌 실천적 판단이긴 하지만, 아직까지 법적 판단은 아니다.¹³⁴⁾ 또한 질서정연한 국제공동체에 서라면, 어떤 행위가 바람직한지를 판단할 때의 주된 증거들은 전체 국제 공동체 및 개별 구성원의 ‘공동선’(정의와 권리를 포함하여)이라고 주장한다.¹³⁵⁾ 이 지점에서 자연법론자로서 피니스의 면모가 잘 드러난다. 결론적으로 피니스의 관습의 권위 설명은, 관습법 개념에 대한 더욱 발전된 이해를 제공할 뿐만 아니라, (본고 제3장에서 논한) 두 가지 차원의 관습법의 역설 문제 — 엘리트주의로의 전략 현상과 선결문제의 오류 — 를 해소하는 데 큰 역할을 한다.

3. 미래지향적 법원으로서 관습

(1) ‘법의 이름으로’: 관습법의 양가성

그렇다면 이제는 관습법의 정당화 문제로 넘어가보자. 본고 제2장과 제3장을 통해 필자가 일관되게 지적해온 점 중 하나는, 법규범으로서 관습법이 갖고

132) ‘X가 권위를 갖는다’는 진술의 세 가지 의미와 유형, 진술의 속성을 밝혀내면서, 이들 사이에 나타나는 차이는 규범적 진술 전 영역에 걸쳐서 등장한다고 한다. 그리고 이 세 가지 유형의 진술 또는 권위 인정의 형식들을 기술적으로 세밀하게 구분하는 것이 중요한 이유를 ‘공동선에 의거한 설명’으로 답한다.

133) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 238-244.

134) 가령 국제사회에서 다자조약의 내용이나 국제기구의 결의들이 관습법의 원천이나 증거라고 종종 일컬어지곤 하는데, 여기서 말하는 조약 결의는 기존의 법이 무엇인지에 대한 견해의 증거가 아니라 위의 두 판단에 표현된 제한적 의미에서 ‘법적 확신’의 증거라는 점을 피니스는 지적한다.

135) 물론 우선순위가 실제로 바뀌거나 역전되기도 하지만, 그러한 사실이 관습법 형성에 있어 장애물일 수는 있지만 도저히 극복 못할 정도는 아니라고 한다. Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 238-244.

있는 양면성이다. 비유하자면, 마치 ‘지킬박사와 하이드’나 ‘자웅동체’처럼, 법 규범으로서 관습의 특징과 위상은 본질적으로 이중적이다. 진정한 의미에서의 법적 관습은 상향식 메커니즘에 따라 형성된 자생적인 규범적 질서로서 민중성, (직접)민주성, 유연성, 개방성, 탈중심성, 역사성, 호혜성과 상호작용성 등을 고유한 특징으로 한다. 하지만 이러한 미덕은 ‘법’이라는 렌즈를 통해 바라보면 오히려 문제적이거나 극복의 대상이 되는 단점이 되기도 하는 것이다. 관습의 고유한 장점과 특유성들은, 마치 같은 동전의 뒷면과도 같이, 비결정성(모호성과 애매성), 불확실성, 비체계성, 산발성, 임의성(arbitrariness)과 비합리성 등으로 (때로는 부당하고 부적절하게) 재인식되어 결국 그것의 법적 지위를 불안정하게 만들고 많은 비판과 우려를 낳기도 한다. 그렇다면 우리는 관습법의 이러한 이중성이나 양면성을 어떻게 해석하고 다루어야 할 것인가? 과장하지도 간과하지도 않으면서 선택하고 포용하는 것, 그러한 태도와 삶의 자세가 필요하다.

생각건대, 필자는 관습법이 내포하는 그러한 미덕과 고유한 가치를 보존하면서도, 불가피하게 수반되는 ‘법으로서’ 갖는 한계와 취약점은 최대한 감축하고 보완할 수 있는 방안을 모색함으로써, 그것이 갖는 잠재성을 온전히 실현할 수 있기를 바란다. 이러한 지향점을 안고 관습법의 법규성 문제를 다시 바라보게 되면, ‘법원으로서 관습’ 명제를 정당화하기 위한 핵심은 실정법으로서 그것의 존재 형식이나 절차에 있지 않음을 알 수 있다. 중요한 것은 형식적·절차적 정당성이라기보다는, 오히려 관습 규범이 우리의 법실천의 장(場)이나 법적 추론에서 수행하는 기능과 역할에 있다.¹³⁶⁾ 결국 관습 규범의 ① 형성 차원과 ② 존속 및 발전의 두 차원에서 모두, 우리는 살아있는 규범으로서 관습 규범이 형성, 실천되고, 작동하고, 기능하는 역동적인 과정에 주목할 필요가 있다. 다른 한편으로는 관습의 형성과 실천 주체인 공동체 구성원들에게 그것이 규범으로 ‘수용’되고 ‘내면화’되는 내적 측면,¹³⁷⁾ 나아가 조정 규범으로서 실제적인

136) 이 점은 본고 제4장 제1절에서 관습을 구성하는 개념소인 관행을 ‘실천적 추론 과정에서 일종의 매듭’ 역할을 하는 기능체로 인식하자는 필자의 관행주의적 주장과도 연결된다.

137) ‘규범의 내면화’와 ‘수용성’을 중심으로 법규성을 인식하고 승인하자는 여기서의

행위 향도 규범이나 조정 문제의 해법으로 기능하는 외적 측면¹³⁸⁾을 중심으로 관습의 법규성을 인식하고 평가할 필요가 있다. 이러한 점은, 제4장 제1절에서 제안했던 두 관계식 - ① 관습 정식 [T1]: “관습 $\Leftarrow$ 관행 * 습관(화)”와 ② 관행 정식 [T2]: “관행 $\Leftarrow$ 규범적 규칙 * 사회적 실천 $\Leftarrow$ 규범적 실천”-과 함께 필자가 강조했던 ‘관행주의적 분석’이나 ‘실천 중심적 접근’과도 궤를 같이한다고 볼 수 있다.

(2) ‘메타-관습’을 통한 정당화

관습의 본질과 법규성을 그것이 법실천의 장이나 법적 추론의 과정에서 수행하는 기능을 중심으로 이해할 필요가 있다는 주장에 동의한다면, 우리는 다시금 피니스의 권위 논변으로 돌아가 관습법을 정당화¹³⁹⁾하기 위한 유용한 이론적 자원을 구할 수 있을 것이다. 이는 일종의 ‘기능주의적 정당화’로 볼 수 있다. 물론 기능주의 논변이 갖는 한계도 적지 않지만, 적어도 관행주의적·실천 중심적 관점에서 본다면 이러한 접근이 적절하고 유익한 출발점이 될 수 있겠다. 결론부터 말하면, 피니스는 “관습-형성을 권위적 규범의 원천으로 다루는 ‘근본틀’ 실천(‘framework’ practice)”¹⁴⁰⁾ 개념을 제안하고, ‘공동선’의 증진이라는 가치와 결합하여 관습법의 정당화를 시도한다.

주지하듯이, 피니스의 법이론에서는 ‘공동선’과 ‘실천적 합당성’이 핵심적인 역할을 한다. 피니스는 행위조정 문제에 대한 해결과 공동 목표의 달성, 혹은 공동선의 증진을 추구하는 조정적 법관념을 주장한다. 그는 공동체 구성원들은 공동선을 달성하고, 그들의 더 나은 행위조정의 방법을 항상 찾고 있으며,

주장은, 본고 제2장에서 필자가 하트(H.L.A. Hart)의 실증주의를 논하면서 핵심적으로 강조했던 특징이기도 하다. 즉, 이 지점에서도 본고 제2장과 제4장의 주제 의식이 통합된다.

138) 여기서 필자가 ‘외적 측면’ 이라고 이름 붙인 것은, 기존의 법실증주의자들이 강조해온 규칙의 외적 측면과는 다른 의미를 담고 있음에 유의하자.

139) ‘관습법의 개념’ 문제와 ‘관습법의 권위 정당화’의 문제는 구별된다. 전자의 문제가 주로 관습법의 성립요건과 결부되어 논의된다면, 후자는 (법철학 주제와 연관지어 보면) 법효력론이나 법가치론의 주제들과 연결된다.

140) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, p. 244.

공동의 목적과 공동선에 대한 구성원들의 충성과 헌신이 크면 클수록 그만큼 더 권위의 필요성은 커진다고 주장한다.

우선, 피니스의 권위 관념을 간단히 재확인해 보자. 피니스는 권위에 따른다는 것을 무비판적인 순응주의와 구별하면서, 숙고된 실천이성의 결론으로서 권위를 말한다. 피니스는 'X가 권위를 갖는다'는 진술의 핵심 의미는, 화자인 S1이 자신을 포함하여 관계자 모두에게 X (또는 X의 발언)에 따라 행동할 배제적 이유를 제공하는 것으로 간주하는 것이라고 설명한다. 피니스는 세 가지 유형의 권위 인정 진술이나 발화-당사자인 S1, 관찰자인 S2, 그리고 제3자(가치중립적 진술을 하는 법률가 관점)인 S3-를 구분하면서 동시에 공동선에 기한 설명을 제공함으로써 실증주의적 반론에 대해 반박한다. 또한 권위와 규범에 대한 핵심적 진술은 S1유형이라고 말하면서, 자신은 실질적인 실천철학을 추구하며 정당화 성격을 갖는 설명에 이론적 관심이 있다고 한다. 피니스는 이런 세 유형의 권위 진술을 구분하는 것은 권위의 필요성, 정당화, 권위의 한계와 적절한 작동방식을 논하는 데 꼭 필요하다고 지적하면서, 그 물음들에 대해 공동선에 의거한 답을 제시한다.¹⁴¹⁾

피니스는 '관습'이란 용어를 '법적으로 권위 있는 관습 규칙'의 축약으로 사용한다. 어떤 관습이 권위 있는 법규범으로 존재한다는 진술은 해당 규범이 관련 사안의 모든 행위자들에게 정당화된 요구를 부과한다는 견해를 표명한다. 피니스에 따르면, 법규범으로서의 힘은 ① 행위 향도력(action-guiding)과 ② 요구사항을 부과(requirement-imposing)하는 두 측면을 갖는데, 어떤 관습이 이 두 가지 법규범력을 정당하게 갖추고 있다면 그 관습의 권위는 정당화된다. 결론부터 말하자면, 국제관습법의 경우 그 권위 있음은 국제사회의 요구와 관련된 '실천적 합당성에 대한 메타-법원리(meta-legal principle of practical reasonableness)'로부터 파생된다. 이 점이 관습법 형성에 관한 설명에 담겨 있는 진정한 문제인데, 이는 관습법의 권위 진술에 관한 추론에 숨겨져 있는 전제로서 '메타-법원리' 또는 '근본틀 원리(framework principle: PJm)'라고 그는 명명한다.

141) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 234-236.

PJm—관습 규칙의 등장과 그에 대한 승인은 국제 공동체에서 상호작용 혹은 조문제를 해결하는 바람직하거나 적절한 방법이다.¹⁴²⁾

피니스는 이 메타-원리PJm을 ‘근본틀 관습(framework custom)’이라고도 칭하면서, 그것의 권위성(authrotativeness)은 후속 관습으로부터 도출되는 것이 아니라 공동선을 증진하는 기회로부터 도출된다고 한다. 또한 그 기회는 이 근본틀 관습에 대한 광범위한(반드시 보편적이지는 않은) 승인에 의해 가능하다.¹⁴³⁾ 요컨대, 관습법이 형성될 수 있는 것은 특정 규칙이 바람직하다는 개별 판단과 이에 대한 공동체 내 합의에 기초하는 것이 아니라, ① 위의 ‘메타-법원리PJm’에 대한 폭넓은 합의와 승인이 있고, ② 관습 규칙이야말로 이에 대한 유일하게 실현 가능한 해법이라는 점에 대한 합의에 의거한다.¹⁴⁴⁾ 피니스는 이러한 두 조건에 대한 합의를 얻는 것이 특정 규칙에 대한 개별적 합의를 통한 정당화보다 훨씬 더 쉽다고 역설한다.¹⁴⁵⁾

그렇다면, 피니스의 이러한 ‘메타-법원리 논변’ 혹은 ‘근본틀 관습 논변’이 갖는 장점은 무엇일까? 첫째, (피니스 자신도 자부하듯이) 메타-법원리(PJm)을 명확히 식별함으로써 관습법의 형성과정과 성립조건에 관한 역설이나 순환논법에서 벗어날 수 있다. 둘째, 실제로 해당 관습 규범을 대다수 국가들이 인식하고 승인함으로써 보편적 준수가 이뤄지고 있다는 경험적 판단에 대해 응당한 고려와 대

142) PJm 개념과 의미는 매우 중요하기에 원문 전체를 옮긴다.;

“PJm—the emergence and recognition of customary rules (by treating a certain degree of concurrence or acquiescence in a practice and a corresponding opinio juris as sufficient to create such a norm and to entitle that norm to recognition even by states not party to the practice or the opinio juris) is a desirable or appropriate method of solving interaction or co-ordination problems in the international community.” Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, p. 243.

143) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, p. 244.

144) 국제사회는 상호작용의 문제와 행위조정의 문제를 해결할 방법이 필요하다는 판단에 대한 합의, 그리고 관습법이 그러한 문제를 해결하는 데 적절하다는 충분한 승인이 있다면 관습법은 적절한 해결책(왜냐하면 관습법이야말로 유일하게 실천 가능한 해결 방법이기 때문에)이라는 판단에 대한 합의를 획득하는 편이 훨씬 쉽다.

145) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 238-244.

우를 한다. 또한, PJm을 표현하는 이와 같은 방식은 메타-법원리인 PJm 승인이 바람직하거나 적절한지에 대한 평가 문제가 PJm을 승인하는 국가들의 수가 충분한지에 좌우된다는 점도 분명히 보여준다. 셋째, 관습 규범의 권위성을 논증하기 위해 실질적인 도덕 규칙이나 정의 등에 직접 호소하는 도덕적 논변으로 나아가지 않아도 된다. 이는 증명이나 논증 부담의 면에서 큰 이점이 있다. 넷째, 무엇보다 가장 중요하게는, 이 ‘메타-법원리’, 혹은 ‘근본틀-관습’을 승인함으로써 국제사회의 호혜적 상호작용과 조정 문제 해결에 기여하고, 모든 국가들에게 국제사회의 공동선을 증진할 기회를 제공한다는 점이다. 다섯째, 개별 관습 규칙의 실질적인 내용 판단이나 심사가 관건이 아니라는 것은 달리 보면 개방성과 포용성을 함축하기에 불확실하고 급변하는 미래공동체의 법규범 승인의 면에서 문턱을 낮추는 실익이 있다고 볼 수 있다.

다만, 국제관습법을 대상으로 한 이러한 논변을 수용하는데 있어서는 적어도 두 가지 추가적인 고려가 필요하겠다. 우선, 이 논변을 과연 국내법질서의 차원에도 그대로 적용할 수 있는지이다. 탈중심적이고 분권적인 성격을 갖는 국제공동체와는 달리, 국내법체계는 법창설의 임무를 부여받은 제1의 국가기관, 즉 입법부가 존재한다는 점에서 중요한 사실의 차이가 있다. 둘째, 피니스가 관습법 논의를 매개로 하여 궁극적으로 강조하려는 바, 즉 “공동선을 증진할 기회가 제공된다는 점이 법적인 모든 권위(그것이 통치자의 권위이건 법규범의 권위이건 상관없이)의 근원”¹⁴⁶⁾이라는 주장에 대해서도 법이론적 입장에 따라 다른 평가가 가능할 수 있다. 다만 분명한 것은, ‘메타-법원리’ 혹은 ‘근본틀-관습’을 통한 정당화 시도는 기존의 제도적 권위 —입법적 권위와 사법 권위— 에 의탁하지 않으면서도, 그것의 법규성의 근거를 모색해보려는 본고의 문제의식에 비취볼 때 중요한 시사점과 자원을 제공한다는 것이다.

(3) ‘오래된 미래’, 그 이름 관습

오늘날 제정법 중심주의를 특징으로 하는 근대법체계에서, 불문의 관습법에는 종종 ‘미운오리새끼’의 혐의가 덧씌워지곤 하는데, 미래사회에서는 ‘백조’가 되어 날아올 수 있는 재원일지 어찌 아는가?

146) Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, p. 244.

근대라는 특수한 시대에 시대적 요청으로서 법전화(codification)는 국가의 중요한 과제 중 하나였고, 그러한 관점에서 볼 때 불문의 비정형적인 형태로 존재하는 관습법은 전근대적 법원이라는 평가를 받기도 해왔다. 하지만 오늘날 입법 현실이나 급변하는 사회 여건을 볼 때, 성문법제화가 더 이상은 어떤 규범을 법으로 자격화하는 데 필수적인 요구사항이 될 수 없으며, 그 시효가 다했다는 냉소적인 평가도 가능하다. 다른 한편으로 보면, 성문법의 경직성과 고정성은 법적 안정성을 보장할 수는 있지만 변화에 기민하게 대응하기에는 역부족인 경우가 많다. 반면 불문의 관습법은 형식적인 면에서 불확실성과 비결정성을 내포하기는 하지만, 그것이 오히려 더 많은 가변성과 다양성을 담아낼 수 있는 ‘가능성의 그릇’으로 이해될 수도 있다. 즉 고정된 성문법과 변화하는 사회 사이의 간극을 메우는 기능을 수행¹⁴⁷⁾하는 것은 유연성과 개방성을 내포한 연성법으로서 관습법이다. 이렇듯, 그 규범의 존재 형식이나 제도화의 절차보다는 그 역동적 과정이나 기능에 더 주목해 본다면, 관습법이야말로 가장 미래지향적인 법원일 수 있는 것이다. 또한 과거 오랜 기간에 걸쳐 형성된 역사적 산물로서 관습법을 바라보는 통상의 이해방식은 관습법을 과거지향적이고 회고적이며, 시대착오적 법원이라는 선입견을 형성해 왔다. 하지만 본고에서 지금까지 살펴본 바와 같이, 만약 관습의 본질을 동적이고 기능적이며, 실천 중심적인 관점에서 바라본다면, 구태의연한 과거의 유물이 아닌 역설적으로 가장 미래지향적이고 민주적인 법원으로 관습법을 새롭게 재규정할 수 있을 것이다. 즉, ‘오래된 미래’, 그 형용 모순 속에 진정한 통찰과 가능성이 잠재되어있다고 볼 수 있다. 관습법의 이러한 잠재적 역량에 주목하고, 그것을 이론적으로 해명하고 정당화하려는 한 시도가 이 글의 또 다른 한 부분을 이루었다.

147) 권영준, “법률행위로 인한 관습법상 법정지상권 폐지와 법정임대차 도입”, 4면.

V. 맺으며: 관습법철학¹⁴⁸⁾을 향하여

1. ‘제정법 만능주의’를 넘어

최근 분묘기지권과 관련하여 우리 대법원의 전원합의체 판결이 내려졌고, 이로 인해 관습법에 관한 논의와 후속 판례들이 이어지고 있다. 그런데 필자는 관습법과 관련한 우리 최고법원들의 판결문을 분석하면서 일부 이상한 점을 발견하였다. 대법원 판결문 중 일부, 그리고 그 전에 있는 헌법재판소의 관습법 위헌심사 결정문에서 공통되게 발견되는 하나의 특징으로서, 분명 관습법에 관한 분석과 논증인데 제정법에 관한 법리와 분석들이 그대로 적용되고 있다는 점이다. 말하자면 ‘제정법 중심주의’를 넘어 ‘제정법 일원주의’와 같은 인상을 지울 수 없을 만큼, 불만족스러운 부분이 적잖았다. 관습의 본질과 관습법 그 자체에 대한 부정확하고 불충분한 이해 때문에 빚어진 과오라고 생각한다. 그리고 또 다른 한편으로는, 최고법원 판결문에서 확인되는 제정법중심의 관습 분석이 벤담식의 고전적 법실증주의자들의 환원주의적 분석(reductivist analysis)과 상통한다는 점이다. 결국 관습의 특유성이나 관습법의 독자성을 부정하고 입법이나 사법이라는 국가권력기관의 권위로부터 규범력을 이식받고 기생함으로써 법적 지위를 보장받는다거나 할까? 이렇듯 실정법학과 법실무에서의 관습의 법적 지위에 관한 불완전하고 부적절한 논증은 법철학에서의 실증주의 논쟁과 결국 만나게 되는 것이다. 그래서 법철학자의 눈으로, 법철학의 관점에서 양자를 가교하여 소통하게 함으로써 보다 나은 해법을 궁구해 보려는 하나의 시도가 본 연구이다.

148) ‘관습법철학’이란 표현은 샤우어의 용어를 참고했다. Schauer, “The Jurisprudence of Custom”. 하지만 이 글에서 필자가 제안하는 ‘관습법철학’은 샤우어가 법실증주의 틀 안에서 천착한 문제의식과 탐구 범위를 넘어서, 관습 그 자체에 법철학적 주제와 사유법을 적용하는 것까지 이른다.

2. 범법래학,¹⁴⁹⁾ 그리고 ‘관습법철학’을 향하여

“법철학에서 관습이 왜 중요한가?” 우리는 이 물음을 던지면서 글을 시작했다. 그리고 관습 그 자체를 본격적인 법철학적 탐구의 주제로 삼았다. 그럼 이제 답을 내려야 할 시점에 온 것 같다.

필자는 관습의 본질과 범규성에 대한 올바른 이해를 구하기 위하여 크게는 두 가지 방식의 접근을 하였다. 우선, 제2장과 제3장에서는 기존의 이론가들의 논의 틀 안에서 관습에 대한 올바른 이해를 구하기 위한 비판적 검토와 일종의 수정주의적인 교정 시도였다면, 제4장과 제5장은 기존의 틀에서 벗어나서 새로운 이론 모델과 대안을 모색하는 적극적인 입론으로 나아갔다. 애초의 목표에 비해 많은 부분이 여전히 불충분하게 미완의 상태로 남아있지만, 그래도 이러한 시도를 통해 “법원으로서의 관습”의 의미에 대한 보다 풍부하고 적절한 이해에 도달할 수 있기를 바란다. 그리고 다른 한편으로는, 관습이 구태의연하고 시대착오적인 전근대적 법원으로, 일종의 과거청산의 대상으로 폄하되는 일부의 인식과 현실에 대해 본 연구가 조금은 긍정적인 기여를 할 수 있기를 희망한다. 다시 한번 강조하건대, 연성범규범으로서 개방성과 유연성, 그리고 구성원들 간의 상호작용을 무엇보다 소중히 여기는 관습범규범은 법의 본성과 규범성에 대한 우리의 이해에 깊이 있는 통찰과 시사점을 제공해 줄 수 있다. 그리고 점차로 급변하고 불확실성이 증대되는 미래사회에 적합한 법원으로서도 관습법은 유용한 잠재적 자원이 될 수 있는, 말하자면 ‘과거청산’의 대상이 아닌 ‘미래지향적’인 법원으로 복권될 수 있음을 조심스레 전망해 본다.

마지막으로, 결론을 대신하여 필자는 ‘관습법철학’을 제안하고자 한다. 필자가 그리는 관습법철학은 ① 관습에 ‘대한’ 법철학적 탐구와 ② 관습을 ‘통한’ 법철학의 발전, 이 두 목표를 양대 축으로 삼아 정립해나갈 기초법학이 될 것이다. 이는 본고의 제목이기도 한 “법철학에서 관습이 왜 중요한가?”라는 질문에 대한 답안의 기본 형식일 수 있으며, 동시에 본 연구를 통해 필자가 밑그림을

149) 참고로, 김현철 교수는 ‘삶의 기제로서 법철학’의 임무를 말하면서, 법철학의 하위 범주로 ‘법철학적 범평가학’과 ‘법철학적 범법래학’을 제안한다. 김현철, “법철학의 주제 설정”, 『법철학연구』, 2019.

그리고자 한 미래법학 일면인지도 모르겠다. ‘법철학의 창(窓)’을 통해 관습의 본질과 법규성을 새롭게 이해하고, 동시에 법철학의 지평을 확장할 수 있기를 바랐으나 늘 그렇듯 남는 것은 부끄러움과 아쉬움뿐이다. 이 글에 미처 담지 못한 부분은 후속 연구로 꼭 이어갈 것을 약속드리며, 부족한 글을 맺는다.

참고문헌

I. 국내문헌

- 강태경, “론 I. 폴리의 유노믹스”, 『법철학연구』, 2017.
- 강태경, “‘내적 관점’의 중층 구조”, 『법철학연구』, 2018.
- 고봉진, “관습헌법의 존재와 효력 — ‘신행정수도의 건설을 위한 특별조치법 위헌결정’을 중심으로”, 『법과 정책』, 2015.
- 권경휘, “현대법실증주의와 규범성의 문제: 하트의 ‘내적 관점’을 중심으로”, 『법철학연구』, 2015.
- 권경휘, “승인의 규칙에 관한 하트의 이론”, 『강원법학』, 2015.
- 권경휘, 김정오, “존 오스틴의 생애와 법사상”, 『법철학연구』, 2018.
- 권영준, “법률행위로 인한 관습법상 법정지상권 폐지와 법정임대차 도입”, 『민사법학』, 2014.
- 김기창, “성문헌법과 ‘관습헌법’”, 『공법연구』, 2005.
- 김건우, “하트의 내적 관점이란 무엇인가?”, 『법철학연구』, 2013.
- 김도균, “자연법론적 승인율 모델의 가능성”, 『법철학연구』, 2000.
- 김도균, “자연법론적 승인율의 필연성에 대하여”, 『법철학연구』, 2001.
- 김상걸, “입법적 국제관습법과 법적확신 개념의 재구성”, 『국제법학회논총』, 2020.
- 김현철, “하트 법이론의 철학적 의의에 대한 비판적 고찰”, 『법학논집』, 2007.
- 김현철, “법철학의 주제 설정”, 『법철학연구』, 2019.
- 김형석, “실증주의와 공리주의의 연결고리-존 오스틴의 명령으로서의 법 개념”, 『법학논총』, 2019.
- 김화진, 『국제법이론』, 박영사, 2017.
- 박정훈, 『행정법의 체계와 방법론』, 박영사, 2005.
- 박준석, “조셉 라즈의 권위론에 대한 비판적 고찰”, 『법철학연구』, 2007.
- 박준석, “관행과 법의 지배”, 『법철학연구』, 2013.
- 박준석, 『법사상, 생각할 의무에 대하여』, 아카넷, 2015.
- 손경찬, “상속회복청구권의 시효에 관한 관습법 실증”, 『법사학연구』, 2019.
- 심헌섭, “권위에 관하여 — 배제적 법실증주의에서 포용적 법실증주의으로”, 『분석과 비판의 법철학』, 법문사, 2003.
- 심희기, “일제강점기 초기 ‘식민지관습법’의 형성”, 『법사학연구』, 2003.
- 심희기, “전통사회의 관습법 개념에 대한 비판적 검토 — 일본식민지 당국에 의한 관

- 습조사를 중심으로”, 『법사학연구』, 2012.
- 안준홍, “승인규칙의 규범성에 대한 일 고찰”, 『법철학연구』, 2013.
- 양선숙, “수도-서울 명제의 ‘관습헌법’성립에 대한 비판적 검토”, 『법철학연구』, 2006.
- 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해”, 『법철학연구』, 2012.
- 양천수, “초국가적 법다원주의 -개념적 차원과 규범적 차원을 중심으로 하여”, 『법철학연구』, 2008.
- 양천수, “새로운 법진화론의 가능성”, 『법철학연구』, 2012.
- 오세혁, “관습법의 현대적 의미”, 『법철학연구』, 2006.
- 오세혁, “관습법의 본질과 성립요건에 관한 고찰-관련 판례에 나타난 논증에 대한 분석 및 비판”, 『홍익법학』, 2007.
- 이상돈, “전문법-이성의 지역화된 실천”, 『고려법학』, 2002.
- 이승일, “일체의 관습조사와 전국적 관습의 확립과정 연구 — 『관습조사보고서』의 편찬을 중심으로”, 『대동문화연구』, 2009.
- 이계일, “법관법의 대상영역과 규범적 힘에 관한 연구”, 『법학연구』, 2016.
- 이계일, “법관법의 법원성에 대한 유형적 탐구”, 『법철학연구』, 2016.
- 이계일, “법관법 변경의 효력범위 설정에 대한 비판적 탐구 — 아울러, 법관법의 법원성 및 변경조건 논의와의 상관관계를 중심으로”, 『법철학연구』, 2021.
- 이상영, “법실증주의의 선구자 J. Bentham은 이상주의자인가 혹은 현실주의자인가?”, 『법사학연구』, 2018.
- 이상영, “벤담의 Common Law 체계에 대한 비판과 입법론 구상에 대한 연구”, 『서울대학교 법학』, 2008.
- 이상영, “벤담의 법개념과 입법론에 대한 소고”, 『세계헌법연구』, 2007.
- 이정훈, “법실증주의 승인율과 관행에 관한 연구”, 『법철학연구』, 2007.
- 이현경, “법학적 관행 이론 소묘: 관행의 규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로”, 『법철학연구』, 2017.
- 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰”, 『법학논총』, 2017.
- 이현경, “법적 관행의 개념과 그 요건”, 『법학논총』, 2017.
- 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소 — 관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초”, 『법철학연구』, 2017.
- 임미원, “대법원의 유체인도 판결의 법철학적 고찰”, 『법조』, 2013.
- 임미원, “탈관습적 시대의 규범적 논거들의 계보”, 『한양법학』, 2013.

- 장영민, “하트-풀러 논쟁 50년 회고”, 『법학논집』, 2007.
- 정경수, “국제관습법의 기본토대로서 국가실행 개념의 재인식”, 『국제법학회논총』, 2004.
- 정궁식, “조선민사령과 한국 근대 민사법”, 『동북아법연구』, 2017.
- 정인섭, 『신국제법강의: 이론과 사례』, 박영사, 2020.
- 조홍식, 『사법통치의 정당성과 한계』, 박영사, 2009.
- 최봉철, “풀러의 합법성론”, 『법철학연구』, 2004.
- 최봉철, “법의 효력: 요건과 효과를 중심으로”, 『법철학연구』, 2014.
- Arthur Kaufmann (김영환 옮김), 『법철학』, 나남, 2007.
- Felix Ravaisson (최화 옮김), 『습관에 대하여』, 자유문고, 2016.
- Georg Jellink (김효전 옮김), 『일반 국가학』, 법문사, 2005.
- H.L.A. Hart (오병선 옮김), 『법의 개념』, 아카넷, 2001.
- Jeremy Waldron (송성국 옮김), “규범적 (또는 윤리적) 실증주의”, 『법철학연구』, 2017.
- Lon. L. Fuller (송성국, 김혁기 옮김), “실증주의 그리고 법에 대한 충실성-하트 교수에 대한 답변”, 『공익과 인권』, 2007.
- Lon. L. Fuller (박은정 옮김), 『법의 도덕성』, 서울대학교출판문화원, 2015.
- Joseph Raz (권경휘 옮김), “권위, 법 그리고 도덕”, 『법철학연구』, 2009.
- Joseph Raz (권경휘 옮김), “법의 본성에 관한 문제”, 『법철학연구』, 2007.

II. 국외문헌

- Andrei Marmor, “The Nature of Law”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2019.
- Anthony D’Amato, “New Approaches to Customary International Law”, *The American Journal of International Law*, 2011.
- Antonino Rotolo, “Sources of Law in the Civil Law”, in *Legal Institution and the Sources of Law*, Edited by Roger A. Shiner, Springer, 2005.
- C.K. Allen, *Law in Making*, 7th ed., Oxford University Press, 1964.
- Curtis A. Bradley, “Customary International Law Adjudication as Common Law Adjudication”, in *Custom’s Future: International Law in a Changing World*, Cambridge University Press, 2016.
- David J. Bederman, *Custom as a Source of Law*, Cambridge University

- Press, 2010.
- David Lefkowitz, "Customary Law and the Case for Incorporationism", *Legal Theory*, 2005.
- David Lefkowitz, "(Dis)solving the Chronological Paradox in Customary International Law: A Hartian Approach", *Philosophy Faculty Publications*, 2008.
- Francesco Parisi, "Spontaneous Emergence of Law: Customary Law", *Encyclopedia of Law & Economics*, 2000.
- Francesco Parisi, "Customary Law", in *The Encyclopedia of Public Choice*, Edited by Rowley & Schneider, 2003.
- Fernado Lusa Bordin, "A Glass Half Full?: The Character, Function and Value of the Two-Element Approach to Identifying Customary International Law", *International Community Law Review*, 2019.
- Frederick Schauer, "The Jurisprudence of Custom", *Texas International Law Journal*, Vol. 48, 2013.
- Gerald J. Postema, "Custom, Normative Practice, and the Law", *Duke Law Journal*, Vol. 61, 2012.
- Gerald J. Postema, "Coordination and Convention at the Foundations of Law", *The Journal of Legal Studies*, Vol. XI, 1982.
- Gerald J. Postema, "Custom in International Law: a normative practice account", in *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007.
- Gerald J. Postema, "Conventions at the Foundations of Law", in *The New Pargrave Dictionary of Economics and The Law*, Edited by Amanda Perreau-Saussine and James Bernard Murphy, Macmillan Reference Limited, 1998.
- Gerald J. Postema, "Salience Reasoning", *Topoi*, 2008.
- Gerald J. Postema, *Legal Philosophy in the Twentieth Century; The Common Law World*, (editor Enrico Pattaro) A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence V.11, Springer, 2011.
- H.F. Jolowicz, *Lectures on Jurisprudence*, Ed. J.A. Jolowicz, University of London Legal Series, Institute of Advanced legal Studies, 1963.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3d ed. Penelope A. Bulloch & Joseph Raz & Leslie Green, Oxford University Press, 2012.
- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, 2nd ed., Standford University Press, 1984.

- James Bernard Murphy, *The Philosophy of Customary Law*, Oxford University Press, 2014.
- James Bernard Murphy, “Habit and Convention at the Foundation of Custom”, in *The New Pargrave Dictionary of Economics and The Law*, Edited by Amanda Perreau-Saussine and James Bernard Murphy, Macmillan Reference Limited, 1998.
- Jeremy Bentham , *Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence*
- Jeremy Webber, “The Grammar of Customary Law”, *MCGILL LAW JOURNAL*, Vo. 54, 2009.
- Jeremy Waldron, “Custom Redeemed By Statute”, *Current legal problems*, Vol. 51, 1998.
- John Austin, *Lectures on Jurisprudence of the Philosophy of Positive Law*, Robert Cambell ed., London, John Murray, 5th ed., 1895.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge University Press, 5th, ed. 1995.
- John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed, Oxford University Press, 2011.
- John Finnis, “Law as Coordination”, in *Philosophy of Law*, Oxford University Press, 2013.
- John Tasioulas, “Customary International Law and the Quest for Global Justice”, Amanda Perreau-Saussine & James Bernard Murphy (ed.), *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007.
- Josef L. Kunz, “The Nature of Customary International Law”, *American Journal of International Law*, 1953.
- Joseph Raz, “Incorporation by Law”, *Legal Theory*, 2004.
- Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, 2nd, Oxford University Press, 2009.
- Jules L. Coleman, “Incorporationism, Conventionality, and the Practical Difference Thesis”, *Legal Theory*, 1998.
- Jules L. Coleman, “Inclusive Legal Positivism”, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, 2001.
- Jules L. Coleman, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, 2001.
- Lassa Francis Lawrence Oppenheim, *Oppenheim's International Law*, Vol. I , 8th

- ed., H. Lauterpacht, Lodon: 1955.
- Laurence R. Helfer & Ingrid B. Wuerth, "Customary International Law: An Instrument Choice Perspective", *Michigan Journal of International Law*, 2016.
- Matthew H. Kramer, *Where Law and Morality Meet*, Oxford University Press, 2004.
- Michael P. Scharf, "Seizing the 'Grotian Moment': Accelerated Formation of Customary International Law in Times of Fundamental Change", *Cornell International Law Journal*, 2010.
- Michael Rescorla, "Convention", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2019.
- Nicholas Southwood, "The Authority of Social Norm", in *New Wave in Metaethics*, edited by Michael Brady, Palgrave Macmillan, 2011.
- Nicholas Southwood, "The Moral/Conventional Distinction", *Mind*, 2011.
- Niels Petersen, "Customary Law Without Custom? Rules, Principles, and the Role of State Practice in International Norm Creation", *American University of International Law Review*, 2008.
- Peter E. Benson, "Francois Génys's Doctrine of Customary Law", *The Canadian Yearbook of International Law*, 1982.
- P.J. Fitzgerald, ed., *Salmond on Jurisprudence*, 12nd ed. Yale University Press, 1966.
- R Capitnat, "La costume constitutionnell", *Gazette du Palais*, 1929, reprinted in *Revue du droit public*, 1979.
- Ramio Tuomela, *The Philosophy of Social Practices: A Collective Acceptance View*, Cambridge University Press, 2002.
- Ramio Tuomela, *The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View*, Oxford University Press, 2007.
- Rodrigo E. Sanchez Brigido, *Groups, Rules and Legal Practice*, Springer, 2010.
- Roger A. Shiner, "Law and Morality", in *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, edited by Dennis Patterson, 1996.
- Roger A. Shiner, *Legal Institution and the Sources of Law*, Springer, 2005.
- Stefano Bertea, "Social-Practice Legal Positivism and the Normativity Thesis", in *The Cambridge Companion to Legal Positivism*, Edited by Torben Spaak and Patricia Mindus, Cambridge University Press.
- Steven Walt, "Why Jurisprudence doesn't Matter for Customary International

Law", *William & Mary Law Review*, 2013.

Edna Ulmann-Margalit, *The Emergence of Norms*, Oxford University Press, 1978.

Abstract

Why does Custom matter in Jurisprudence?
—A Fresh Understanding on the Nature and Legality of Custom—

Lee, Hyun-Kyung

Today in the so-called ‘post-customary era,’ custom(ary law) has often been neglected and disfavored in both legal theory and practice. Along with the skepticism that customary law is merely a redundancy in the domestic legal system, the role of custom is often called a ‘jurisprudential puzzle.’ In the philosophy of law, in contrast, customary law is an important subject in many dimensions. For legal positivists, the legal status of customary law has been a dilemma that had to be solved in accordance with their concept of law, the outcome which would the theory’s persuasiveness. In a Fullerian non-positivist perspective, conversely, customary law can be a medium which shows the interactiveness and openness of law. Thus how we cope with custom can be decisive in valuating the coherence and validity of a theory of legal philosophy. In this article, the author first examines the history of legal-philosophical arguments concerning the nature and legal status (II.), and focuses on phenomena of ‘customary laws without customs’ and ‘the paradox of customs,’ which were indicated as troubles by positivists adhering to command theory and in the skeptistic tradition, to point out what makes custom so ‘problematic.’ (III.) The author (i) sets forth the formula of “custom = convention * habit(uation) as the basic framework for a new perspective on the nature of custom(ary law), (ii) with an introduction to Postema’s normative practice account (IV.). As a conclusion the author remarks that a properly reconstructed theory on legal customs can work, instead of a troublesome dilemma, as the basis for a inclusive

concept of law embracing international customary laws in its sphere, and speculates that customary law can —instead of being an outdated source of law— be reshaped as a soft-law norm for future society (VI).

색인어

관습(Custom), 관습법(Customary Law), 관습법의 역설(Paradox of Customary Law), 법실증주의(legal Positivism), 상향식 메커니즘(Top-down Mechanism), 권위(Authority), 관습법철학(Jurisprudence of Custom)